

este tribunal resolvía anualmente 14.903 causas, cifra que se ha ido incrementando notablemente (2). Para ello tenía 192 (3) funcionarios de alta jerarquía que asistían al tribunal en sus decisiones y de una planta total de 2341 funcionarios y empleados administrativos entre las áreas sustantivas, de administración central y las áreas de apoyo, si bien algunas de ellas han pasado a la órbita del Consejo de la Magistratura. Resulta evidente que el excesivo número de causas importa irrazonables demoras en su resolución, que no puede endilgarse como vemos al personal que cumple sus funciones.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en cuya jurisprudencia y funcionamiento se refleja nuestro máximo Tribunal, decide sobre el fondo del asunto entre 70 y 90 casos por año (menos del 1% de las que decide nuestra Corte, en un país con casi ocho veces más habitantes que la Argentina).

Para Sagüés el problema más actual es la efectividad en el modo y forma de obtener una decisión del Alto Tribunal y su legitimidad.

2. FUNCIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

El R.E. tiene como meta principal asegurar la supremacía de la Constitución Nacional a través del control de constitucionalidad; como apoyatura de ello Esteban Imaz y Ricardo Rey agregan que los conflictos cuya solución no afecta a la Constitución Nacional, no constituyen cuestión federal.

Al respecto la Corte ha sido más amplia ya que considera que debe mantener la supremacía de la Constitución en todo el país, que alude esencialmente al control de constitucionalidad de las normas y actos de autoridad nacionales y provinciales.

De ahí que el R.E. sea un proceso constitucional típico, el proceso constitucional por antonomasia del derecho argentino.

3. REQUISITOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

Como regla no hace análisis de cuestiones de hecho, prueba, derecho provincial, y los requisitos, según la ley 48 en su art. 14 son:

(2) Según datos de las estadísticas 2001 del Poder Judicial de la Nación, del total de 14.903 causas falladas, 8468 corresponden a expedientes previsionales (trámites sobre jubilaciones y pensiones). En 2001, ingresaron 14.262 expedientes, 6989 correspondientes a materia previsional. Al 31 de diciembre de 2001 había 10.878 expedientes en trámite (recursos y juicios originarios), con más 8495 previsionales, haciendo un total de 19.373. A la misma fecha de 2000, las cifras en trámite ascendían a 10.030 y 9975 para expedientes previsionales. Los datos muestran un importante stock de expedientes sin resolver que aumentan año a año. En efecto, en 2006, ingresaron 30.544 expedientes, y se resolvieron 14.668, estando en trámite 79.781 causas.

(3) Había en la Corte, además de los jueces (hoy cinco), 11 secretarios del tribunal con cargo equiparable a juez de cámara, 76 secretarios letrados con rango equiparable a jueces, 25 prosecretarios letrados, 21 prosecretarios jefes y 59 prosecretarios administrativos. Fuente:

titucional.

- *Sentencias definitivas*—no haya recurso posible contra esa decisión—o resoluciones equiparables, y
- *Último tribunal de provincia*—reformado implícitamente por la ley 4055 lo es en general en la causa, las Cámara de Apelaciones Nacionales—.

Por vía pretoriana se crean dos más:

- la *sentencia arbitraria*—lo insinuó en "*Rey c. Rocha*" en 1909 (Fallos: 112:384) y lo manifestó en el caso "*Storani de Boidanich*" (Fallos: 184:237) en 1945—. Sirve para atemperar la no existencia de cuestión federal típica.
- *gravedad institucional* ("*Jorge Antonio*" en 1960 —Fallos: 248:189—). Sirve para atenuar la falta de sentencia definitiva y último tribunal de la causa.

En su nueva composición, la Corte en los casos: "*Izcovich*" (2005), "*Verbitsky*" (2005) y "*Mendoza, Beatriz*" (20/6/2006) se pronuncia reiteradamente sobre su rol de tribunal de casación constitucional. En el último caso manifestó en su considerando 14 "in fine" que reviste "... las atribuciones constitucionales que la ley suprema ha encomendado a este cuerpo en los asuntos que corresponden a su jurisdicción más eminente, como intérprete final de aquélla, como guardián último de las garantías superiores de las personas y como partícipe en el proceso republicano de gobierno...".

4. REQUISITOS DEL CONTROL

Para que funcione un auténtico proceso de control constitucional, tres son los requisitos indispensables:

1. Separación: el órgano de control debe ser distinto al órgano controlado.
2. Independencia: el órgano que controla no debe depender de ningún órgano.
3. Constitución total o parcialmente rígida.
4. Facultades decisorias en el órgano de control.
5. Los particulares puedan presentarse por sí mismos.

Argentina: Sistema de Justicia 2001/2002, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos.

209

a) Proyectos de la Convención Constituyente de Filadelfia

Luego de la independencia de los EE.UU. en el año 1776, la primera constitución de los EE.UU. fueron los llamados "Artículos de la Confederación y Unión Perpetua" que rigió desde el año 1781 hasta 1789.

Producto de no poder resolver problemas comerciales e internacionales, en el año 1786, el Congreso de los EE.UU. pidió que enviaran delegados para una Convención a celebrarse en Filadelfia para proponer enmiendas a los Artículos de la Confederación que fortaleciera al Gobierno Central, pero la Convención no agregó nuevas enmiendas, sino que dictó una nueva constitución que fue aprobada por el Congreso Nacional y ratificada por los Estados, y entró en vigencia en marzo del año 1789, fortaleciendo al gobierno central conservando el sistema federal.

Del derecho constitucional estadounidense deriva el control judicial en sentido estricto —órganos situados en la órbita del Poder Judicial—.

Pero en el seno de la Convención Constituyente de Filadelfia hubo varias iniciativas. Wilson y Madison propusieron una suerte de "Consejo de revisión", integrado por el presidente y un número de magistrados, con poder de veto sobre el parlamento.

Otra iniciativa era más operativa y consistía en que toda iniciativa de ley sea remitida al presidente y a la Corte Suprema con facultad, para cualquiera de ellos, de vetarlas. Pero ambos proyectos fueron dejados sin efecto y la constitución guardó silencio sobre el mecanismo de salvaguardia del principio de supremacía constitucional.

b) Competencia federal y estadual (5)

b.1) Aplicación de normas federales y estatales

La mayor diferencia con Argentina la encontramos en que la competencia federal no es exclusiva sino concurrente con la competencia judicial de los Estados. Muchas veces los tribunales estatales deciden cuestiones de Derecho Federal, incluso cuestiones de derecho constitucional federal. Asimismo, los tribunales federales deciden cuestiones de derecho estatal. En ambos casos el federalismo se refleja y se mantiene en el proceso.

Cuando un tribunal estatal decide una cuestión de Derecho Federal, está obligado a seguir (o aplicar) la jurisprudencia de la Corte Suprema de los

(4) MARANIello, PATRICIO A., "El recurso extraordinario y el sistema federal en el sistema de EE.UU.", EIDial - DCBA2, diario del 29/6/2007.

(5) El presente trabajo fue expuesto por PATRICIO MARANIello en el marco del seminario sobre *Derecho Procesal Constitucional* en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el año 2006.

Estados Unidos para resolver la cuestión. Este principio (o *regla de decisión*) está basado en la supremacía federal y en el federalismo.

La otra cara de la moneda es que, cuando un tribunal federal decide una cuestión de Derecho estatal, está obligado a seguir la jurisprudencia del tribunal más alto de aquel Estado. Es decir, el tribunal federal está obligado a interpretar la ley del Estado como la ha interpretado la Corte Suprema de ese Estado, y cuando no existe legislación sobre la materia, el juez federal está obligado a aplicar el derecho común del Estado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal más alto del Estado.

Este principio, conocido como la "*Doctrina Erie*" fue anunciada en el famoso caso "*Erie Railroad Co vs. Tompkins*" decidido por la CS de los EE.UU. en 1938.

b.2) Conflicto entre distintas jurisdicciones y distintas leyes estatales

En el caso "*Pennoyer vs. Neff*" del año 1877 de la CS de los EE.UU. se decidió que la garantía constitucional del "debido proceso legal" que se encuentra en la Enmienda Decimocuarta, limita el poder de los tribunales estatales de conocer y decidir casos contra personas o acerca de reclamos que no tienen relación adecuada con el Estado que tiene el fuero. Es decir debe haber "contactos mínimos suficientes" entre el fuero que corresponde, el demandado y el reclamo, tal como lo decidió la CS de los EE.UU. en el caso "*International Shoe Company v. State of Washington*" de 1945.

Y en los casos de conflicto de leyes, siguiendo nuevamente el debido proceso legal y el principio federalista, la Corte ha interpretado en el caso "*Allstate Insurance Company vs. Hague*", que a pesar de que un Estado tenga jurisdicción para conocer y decidir un caso, un Estado debe aplicar la ley o la jurisdicción de otro estado, cuando éste tiene una relación con el asunto y las partes, mucho más estrecha que la tiene el Estado en donde se llevó el caso.

b.3) Plena fe de las decisiones de los Estados

Serán respetadas las sentencias de los distintos Estados, siempre que el tribunal que dicte la sentencia, tenga jurisdicción sobre la materia y las partes.

c) Comparación entre el control de constitucionalidad y el *common law*

En el año 1610 el juez Coke en el caso "*Dr. Bonham*" dijo en Inglaterra que ninguna ley puede ser contraria a los principios del *common law*. Pero luego del año 1689 se estableció la supremacía del Parlamento y puso fin a la idea de control judicial de las leyes.

En EE.UU. fue a la inversa: el poder soberano del Parlamento se debe subordinar al control de constitucionalidad de las leyes.

Los primeros controles constitucionales lo realizaron las propias trece colonias, bajo su propio sistema, atento a que no tenía poder judicial federal permanente ni un mecanismo de control de constitucionalidad federal.

En la actualidad el control en EE.UU. se realiza tanto a nivel estadual como federal, con preeminencia —como ya se dijo— en relación a las normas locales de la jurisprudencia de los primeros citados.

Y en nuestro país se comenzó con un control de constitucionalidad a cargo del Máximo Tribunal Federal, que luego se fueron incorporando en su control previo los tribunales de la justicia local, pero siempre el órgano superior de control resulta ser la Corte Suprema Federal, como último intérprete de la Constitución.

6. REQUISITOS FORMALES Y EFECTOS

El recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema procederá en los supuestos previstos por el artículo 14 de la ley 48 y en el art. 256 del CPCCN, en cuanto a su aspecto formal.

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario (6).

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Palacios v. Argentina" (Informe N° 105/99, Caso N° 10.194, del 29/9/1999) en el cual dicho organismo sostuvo, con cita aprobatoria del caso "Téllez", que la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de aplicar su nueva jurisprudencia al denunciante, a los efectos de declarar que su demanda era formalmente inadmisibile, había sido violatoria de los arts. 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al fundar su opinión, la Comisión tuvo en cuenta que el particular había promovido su acción ante la Corte Provincial con base en la anterior jurisprudencia de aquel tribunal conforme a la cual su presentación era formalmente admisible (7).

a) Forma, plazo y trámite

El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito, fundado con arreglo a lo establecido en el art. 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que motiva, dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación (art. 257 del CPCCN).

De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por diez días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula.

(6) CSJN, *in re*: "Pulvirenti de Alberte, Elena D. y otros c. Nación Argentina". Fallos: 308:1087.

(7) Ver considerandos 59 y sigtes.; LA LEY, 2000-F, 594.

Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de cinco días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo, a costa del recurrente.

La parte que no hubiera constituido domicilio en la Capital Federal quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el art. 252 del código de rito.

b) Llamamientos de autos

Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos (art. 280 del CPCCN).

c) *Certiorari*

La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia (párrafo segundo del artículo citado).

Con la norma del art. 280 de la ley de rito, agregada en 1990, se consagró entre nosotros el instituto del "*certiorari negativo*". A diferencia de su versión norteamericana, la fórmula sirve entre nosotros para desestimar el recurso en las mentadas hipótesis de insuficiencia o no trascendencia de la cuestión federal planteada.

Alguna corriente doctrinaria ha postulado su inconstitucionalidad, por violación al deber de fundar toda sentencia que trae aparejado el art. 18 CN y el art. 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, con análoga jerarquía (art. 75, inc. 22 CN). Empero, la mayoría de la doctrina se inclina por conceder al Alto Tribunal esta potestad, en tanto y en cuanto se la ejerza de manera razonable.

d) Memorial

El apelante deberá presentar memorial dentro del término de diez días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta de presentación del memorial o su insuficiencia traerá aparejada la deserción del recurso.

Contestado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo se llamará autos. En ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos (según ley 23.774).

211

e) Efectos

Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo (art. 499 del CPCCN).

Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutivo consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio; la resolución del juez que lo acuerde o, en su caso, lo deniegue, es irrecurrible.

7. RECURSO ORDINARIO

Una de las diferencias más significativas, aparte de los requisitos, la encontramos en que el recurso ordinario es propiamente una tercera etapa, es decir, se tiene la posibilidad de abrir la causa a prueba o medidas no realizadas en las instancias anteriores.

a) Requisitos

La Corte se encarga también de revisar causas ya sentenciadas por Cámaras Federales o Nacionales cuando son:

- Causas en que la Nación es parte y el monto del pleito supere los \$462.753,70.
- Pedidos de extradición.
- Apresamiento o embargos marítimos en tiempo de guerra.
- Las causas vinculadas con salvamento militar.
- Legitimidad y regularidad de las patentes de los buques.

b) Forma y plazo

En cuanto a la forma y plazo, el art. 254 del CPCCN establece que: "El recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, en causa civil, se interpondrá ante la cámara de apelaciones respectiva dentro del plazo y en la forma dispuesta por los arts. 244 y 245".

- **Plazo:** No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de cinco días. Toda regulación de honorarios será apelable. El recurso de apelación deberá interponerse y podrá fundarse dentro de los cinco días de la notificación (art. 244 del CPCCN).
- **Forma:** El recurso de apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el secretario o el oficial primero asentará en el expediente. El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el oficial primero pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso (art. 245 del CPCCN).

c) Llamamientos de autos

Si se tratare del recurso ordinario del art. 254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene personalmente o por cédula (art. 280 del CPCCN).

d) Posturas de la CSJN sobre admisión y rechazo del recurso ordinario

A continuación se detallarán los casos más comunes en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación procede a la admisión o el rechazo del recurso ordinario.

d.1) Circunstancias en que proceden

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el valor disputado en último término, o sea aquel por el que se pretende la modificación de la condena o monto del agravio, exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición (8).

El recurso ordinario de apelación ante la Corte funciona restrictivamente, tan solo respecto de sentencias definitivas (9).

d.2) Circunstancias en que no proceden

El memorial debe contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia; tal circunstancia de acuerdo con lo dispuesto por el art. 280, apart. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, trae aparejada su deserción (10).

(8) CSJN *in re*: "Compañía Azucarera Tucumana c. Nación Argentina". Fallos: 308:917.

(9) CSJN, *in re*: "Vicente Robles S.A.M.C.I C.I.F. c. Nación Argentina". Fallos: 308:1636.

(10) CSJN, *in re*: "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Wilco S.C.P.A. Lavezzari Hnos. S.R.L.". Fallos: 308:693.

No procede el recurso ordinario del art. 3, inc. 2, ley 4055, deducido contra una sentencia de la Cámara Federal de Apelación de la Capital, pronunciada en juicio ejecutivo y que no asume en consecuencia caracteres de definitiva (11).

El recurso ordinario no es viable en un caso en que no se ha demandado a la Nación (12).

8. RECURSO DE QUEJA

Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por delegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de australes diez millones. El monto actualizado a la fecha es de \$ 5000 (conf. Acordada 1/07). El depósito se hará en el banco de depósitos judiciales (art. 286 del CPCCN).

No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas.

Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de cinco días. El auto que así lo ordene se notificará personalmente o por cédula.

Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso (según ley 23.774).

9. REQUISITOS FORMALES DE LA ACORDADA 4/07

En el mes de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 4, por la que procedió a reglamentar los recaudos de tipo formal que cabe exigir a la presentación de un recurso extraordinario federal y a una queja.

Las nuevas pautas, que configuraron una "inérita directriz" en palabras de Silvia B. Palacio de Caeiro, se cimentaron sobre la base de la propia ley 48 y en las propias prescripciones de la Constitución. No tenemos duda de que la Corte, al regular la dinámica operativa de un recurso que a la postre va a tramitar ante sus estrados, tiene suficiente espacio y habilitación constitucional para dictar este tipo de reglamentaciones.

Hemos ya señalado que la propia ley 23.774 confiere al Tribunal la potestad en el art. 280 del CPCCN de autorizar el "certiorari negativo", a la usanza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de modo discrecional y con la sola invocación de la norma.

(11) CSJN, *in re*: "Fisco Nacional c. Croce, Agustín A.", del 1/1/1932, Fallos: 166:52.

(12) CSJN, *in re*: "Rojas, José", 1/1/1932, Fallos: 165:184.

Los lineamientos que establece la citada Acordada llegan a actuar como una suerte de "pre-certiorari" o de "certiorari de habilitación", en tanto y en cuanto se requiere el cumplimiento de determinados parámetros de índole exclusivamente formal, como llenar la carátula, la cantidad de páginas en los recursos (40 en el extraordinario, 10 en la queja) y hasta la fuente a utilizar por el procesador de texto.

Evidentemente, la Corte procura ser como ya se dijo "tribunal constitucional" y desplegar una "jurisdicción constitucional eminente". Detrás del sano propósito de reordenar y sistematizar el trabajo forense ante sus estrados, está el no tan velado propósito de preservar su rol institucional para temas realmente candentes y trascendentes. Dentro de esa política, pues, cabe que la Corte ejerza un papel mayor en el control de la forma con que se presentan los escritos, como mecanismo para regular en definitiva los temas de la agenda que va a resolver.

Todas las Altas Cortes (las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales, en los sistemas de control concentrado o centralizado de constitucionalidad) tienen el poder de seleccionar, en más o en menos, las causas en donde se va a expedir. La Acordada de referencia forma parte de esta tónica, que no es patrimonio ni exclusivo ni excluyente de la Corte Suprema argentina. Estos tribunales tienen la ventaja por sobre sus pares de las instancias inferiores, de que tienen el "poder decidir a decidir" que no lo puede en principio hacer un magistrado de grado.

10. AUDIENCIA PÚBLICA

Con el objeto de elevar la calidad institucional y promover el Estado constitucional de derecho la CSJN dicta la Acordada 30/07, el 5 de noviembre de 2007, por la cual con la firma de tres jueces del Máximo Tribunal se podrá convocar a: I) audiencia informativa; II) audiencia conciliatoria; y III) audiencia ordenatoria. Estas audiencias serán públicas.

11. CONCLUSIÓN

En este capítulo no sólo hemos realizado un breve repaso del recurso extraordinario, sino también su comparación con el sistema federal nacional y comparado (13).

(13) Kelsen, Hans, en su celebre libro: *¿Quién debe defender la constitución?* y Carl Schmitt en su libro *La defensa de la constitución?* ambos escritos en la década de 1930, tuvieron la discusión más rica y orgánica de esta cuestión, en momentos que Alemania y toda Europa atravesaba una crisis política-institucional sumamente grave. El primero propiciaba un control concentrado y un tribunal independiente, con un Poder Judicial como único guardián de la Constitución. Mientras que el jurista alemán pregonaba con que el Poder Judicial no puede ser el garante de la Constitución sino el Presidente del Reich y el Parlamento como único curador del derecho, con un control concreto y difuso.

En dicha comparación vemos, que si bien, el sistema federal es tomado y seguido del modelo de EE.UU., notamos que existe una inclusión muy importante del federalismo en la Corte Suprema del país del norte.

Sin embargo en nuestro Estado no se llegan a cumplir con las mínimas exigencias de seguimiento de la jurisprudencia de los máximos Tribunales de provincia por parte de la Corte Suprema de Justicia Nacional, para ser un verdadero Poder Judicial "federal".

Karl Loewenstein en su famoso libro *Teoría de la Constitución*, expresó que "...los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del jardín...", pues el mejor guardián del federalismo es el sistema federal y no una Corte Suprema nacional.

CAPITULO III.2

COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA CSJN

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Casos en que procede la competencia originaria y exclusiva. a) Los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. b) Cuando alguna provincia fuese parte. — 3. Criterios no uniformes. Empréstitos provinciales en la competencia originaria y exclusiva. — 4. Prórroga de competencia en la competencia originaria y exclusiva. — 5. Requisitos de admisión de la competencia originaria y exclusiva. — 6. Casos en que no procede. — 7. Relación con la Ciudad de Buenos Aires. — 8. Derechos ambientales. — 9. La Corte como Tribunal Constitucional. — 10. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Sabemos que para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación existen dos vías: I) la de apelación y II) la originaria y exclusiva.

I) En la primera es decir por apelación, existen siete recursos:

1) El más importante y usado es el "*Recurso extraordinario por cuestiones federales propias*" que desde 1863 en el art. 14 de la ley 48 es el único medio formalmente legislado en la Argentina para hacer prevalecer la solución federativa en los ámbitos jurisdiccionales locales.

2) El "*recurso de revisión*" previsto en los arts. 7º de la ley 27, 241 de la ley 50, 2º de la ley 4055 y el art. 24, inc. 3º del decreto-ley 1285/58, en realidad sólo consiste en un medio limitado de impugnación de los actos de la propia Corte Suprema de Justicia (similar al recurso de revocatoria), y no de aquellos que emanan de los restantes órganos jurisdiccionales del país (1).

3) El "*recurso por denegación o retardo de justicia*", previsto en los arts. 6º de la ley 48 y 24, inc. 5º, del decreto-ley 1285/58, reglamentario de las demoras en pronunciar sentencia en las que incurriesen las "cámaras de apelación" de la federación que tiene una neta raíz constitucional de larga data, como ser en

(1) EGOES, ALBERTO J. Ref.: ED, 11/9/2007, nro 11.838.

el párr. 40 de la Carta Magna inglesa del año 1215. También la Constitución de Cádiz de 1812 contemplaba la celeridad de los tribunales en sus arts. 267 y 287, atribuyendo al Rey la obligación de "cuidar que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente justicia". No es un medio directo de impugnación de las demoras judiciales, ni la Corte Suprema de Justicia lo ha desarrollado en tal sentido.

4) El "recurso ordinario", regulado en el inc. 6° del art. 24 del decreto-ley 1285/58; sólo se concede contra las sentencias de las "cámaras de apelación" de la federación en aquellas ocasiones en las que se encuentra comprometido un significativo interés patrimonial del Estado que así resulta privilegiado, con una última instancia recursiva que niega a sus ciudadanos.

5) El "recurso de queja" previsto en el art. 15 de la ley 48; no constituye un remedio procesal para hacer prevalecer la solución federativa en los ámbitos locales, sino sólo constituye un remedio ante la negación de un recurso extraordinario por las Cámaras de Apelaciones. Se presenta directamente ante el Máximo Tribunal. De allí deriva el nombre de "presentación directa".

6) El "recurso de apelación por cuestiones de competencia y conflictos entre jueces", previsto en el inc. 7° del art. 24 del decreto-ley 1285/58.

7) El "recurso *pers saltum*", aunque muchas veces cuestionado, fue utilizado jurisprudencialmente como por ejemplo en el caso "Aerolíneas Argentinas", Fallos: Además, tuvo su única etapa regulatoria legislativa —aunque sin citarlo expresamente— en la época del corralito financiero con la incorporación del art. 195 bis del CPCCN por medio de la ley 25.561, que fuera derogado por el art. 7° de la ley 25.587. En este último caso, podía utilizarse para medidas cautelares dictadas por los jueces inferiores que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, las municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal. La presentación de este recurso tenía por sí efectos suspensivos de la resolución cuestionada.

II) Competencia "originaria y exclusiva" además de los casos enunciados en los párrafos anteriores la Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene una vía más de acceso dada por la propia Constitución Nacional en su art. 117 (2), que dispone lo siguiente: "En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente". Además del artículo citado, el instituto se encuentra

(2) Con antecedentes históricos en las Constituciones de 1819 y 1826. Ver GÓMEZ ZAVAGLIA, TRISTÁN, su contribución en HOCKL, MARÍA C., y otro, *Competencias y Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, Buenos Aires, 2006, ps. 203/204.

regulado en los arts. 1° de la ley 48; 2° de la ley 4055 y 24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58, que enlaza al art. 117 con el 116 constitucionales.

En efecto, dentro de la jurisdicción federal, la que el art. 101 (actual 117) de la Constitución Nacional confiere a la Corte con carácter de originaria y exclusiva, está limitada por la enumeración del art. 100 (actual 116). Esa enunciación es taxativa y no puede ser ampliada por la ley (3). Es decir, resulta una competencia exclusiva e insusceptible de extenderse por ley (4).

2. CASOS EN QUE PROCEDE LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA

a) Los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros

La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema en todos los asuntos concernientes a embajadores extranjeros responde a la necesidad de preservar el respeto y la mutua consideración entre los Estados, asegurando para sus representantes diplomáticos las máximas garantías que, con arreglo a la práctica uniforme de las naciones, debe reconocérseles para el más eficaz cumplimiento de sus funciones (5).

Con arreglo de lo dispuesto por el art. 24, inc. 1, del decreto-ley 1285/58, la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema comprende no sólo a los embajadores y ministros extranjeros sino también a las personas de su familia y al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático (6).

b) Cuando alguna provincia fuese parte

Para que una causa en la que sea parte una provincia sea sometida a la competencia originaria y exclusiva, se requiere, además, entre otros supuestos previstos en el art. 24 inc. 1° del decreto-ley 1285/58, que la contienda sea un asunto "civil" con vecinos de otra provincia. Esto significa que se requiere que se debatan cuestiones de derecho común, con exclusión de las causas penales y las regidas por el derecho administrativo local (7).

No reviste el carácter de causa civil, a los efectos de la competencia originaria de la Corte Suprema, la promovida contra la Provincia de Córdoba por devolución de derechos arancelarios abonados en virtud de lo dispuesto por el decreto 2827 —Serie A— dictado por el Interventor Federal modificatorio de la ley local 4183 y no ratificado por ley posterior. En el caso, lo debatido

(3) CSJN *in re*: "Rolón y Moroni, Elda Clara c. Provincia de Buenos Aires". 1/1/1972. Fallos: 283:429.

(4) CSJN *in re*: "Sedero de Carmona Ruth c. Buenos Aires Provincia de". 9/6/1987. Fallos: 310:1074.

(5) CSJN *in re*: "Jacobs Klaus Günter". 17/3/1987. Fallos: 310:567.

(6) CSJN *in re*: "Martínez, Enrique Mariano c. Ramos, José Ignacio". Fallos: 284:28.

(7) Fallos 111:102; 250:217; 255:256; 311:2351; 313:1217, entre otros.

215

comprende cuestiones de derecho público local de competencia exclusiva de los jueces provinciales (8).

La Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer originariamente cuando, como en el caso, el vecino de la provincia demandada cuestiona la supuesta colisión de una ley local —5605 de la Provincia de Santa Fe— con leyes nacionales de derecho común —14.250 y 16.459—, dado que la acción no se funda exclusiva y directamente en disposiciones de la Constitución Nacional (voto de los Doctores Roberto E. Chute y Marco Aurelio Risolía) (9).

Para que una causa verse sobre puntos regidos por la Constitución, es necesario que lo debatido en el pleito no comprenda cuestiones de índole local y de competencia exclusiva de los jueces provinciales. Cuando la impugnación que da fundamento a la demanda contra una provincia es doble, esto es, como contraria a la ley local y a la Constitución Nacional, corresponde entender en ella a la justicia local. Es, así, ajena a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema la demanda de repetición de impuestos y multas fundada en la errónea interpretación de las leyes 4834, 5118 y 5246 de la Provincia de Buenos Aires y del art. 12 del Código Fiscal —en la que además de las objeciones de carácter constitucional a las leyes fiscales citadas, se discuten cuestiones de hecho y prueba—, puesto que el reclamo de la actora puede encontrar solución satisfactoria en juicios de repetición en los tribunales provinciales, si éstos comparten la interpretación que aquélla asigna a las leyes cuestionadas (10).

La restricción a la competencia originaria de la Corte Suprema, cuando se debaten cuestiones de índole local de la competencia exclusiva de los jueces provinciales, acontece no sólo en los supuestos en que ha mediado prórroga voluntaria de jurisdicción (11).

3. CRITERIOS NO UNIFORMES. EMPRÉSTITOS PROVINCIALES EN LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA

En los reclamos por empréstitos provinciales, la Corte Suprema no ha mantenido un criterio uniforme. Como señala Aguilar Valdez, tradicionalmente el Alto Tribunal consideró que la relación derivada de estos empréstitos era de naturaleza contractual y de derecho privado, asumiendo su competencia originaria en aquellos casos en que el emisor fuese una provincia, en función de entender que existía una causa "civil" (12).

(8) CSJN *in re*: "Ferrer, Ignacio P. y otro c. Provincia de Córdoba". Fallos: 270:410.

(9) CSJN *in re*: "Industria Electromecánica S.A.D.D. c. Provincia de Santa Fe". Fallos: 271:244.

(10) CSJN *in re*: "Bernberg, Otto Eduardo y otros c. Provincia de Buenos Aires". 1/1/1958. Fallos: 240: 210.

(11) CSJN *in re*: "Limetas S.A. y otras c. Prov. de Buenos Aires". 1/1/1959. Fallos: 245:104.

(12) AGUILAR VALDEZ, OSCAR, "Responsabilidad del Estado por su actividad financiera. Aspectos jurídicos del endeudamiento público", publicado en *Default y Reestructuración de la Deuda Externa*, La Ley, noviembre de 2003, ps. 48 y sigtes.; en especial, p. 60. Este autor cita,

Pero esta situación jurisprudencial varió a partir del caso "Contúpel Cata-marca c. Provincia de Salta" (13), donde la Corte Suprema entendió que el empréstito público provincial era una relación de "inequívoca naturaleza administrativa" (en particular, derivada de un contrato administrativo), declarándose incompetente para entender en instancia originaria (14).

Luego en el caso: "Chiodi, Carlos Aníbal y otros c. Salta, Provincia de y otro s/ acción de amparo" (Fallos: 327:5111), la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide, en primer lugar, declarar su competencia originaria para entender en una acción de amparo promovida por tenedores de títulos de consolidación de la deuda pública en dólares estadounidenses de la Provincia de Salta, contra la pesificación de la deuda pública provincial dispuesta en el decreto 471/2002.

Si bien declaró su competencia, no lo hizo valorando la naturaleza jurídica del empréstito, sino que en este caso no solamente estaba demandada la Provincia de Salta, emisora de los títulos públicos cuyo cobro se perseguía mediante la acción de amparo, sino también el Estado Nacional, puesto que los actores ponían en tela de juicio la validez de disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional (en particular, el decreto 471/2002). Se hace aplicación, entonces, de la jurisprudencia del mismo tribunal cimero que sostiene que en aquellas causas en que sean parte una provincia —a quienes le concierne la competencia originaria de la Corte Suprema, de conformidad con el art. 117 de la Ley Fundamental— y el Estado Nacional —quien tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Const. Nac.—, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en la instancia originaria de ese Alto Tribunal (15).

4. PRÓRROGA DE COMPETENCIA EN LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA

La jurisdicción acordada a la Corte Suprema por los ex arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1), del decreto-ley 1285/58, para conocer en forma originaria y exclusiva en las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, es susceptible de prórroga a favor de los jueces de la Nación. Ello ocurre siempre que la renuncia a dicha jurisdicción

como ejemplos de esta línea jurisprudencial, los casos que se registran en Fallos 138:37, 138:402; 143:175; 149:226; 149:243; 151:59; 171:9; 192:366; 197:601; 198:13; 198:369; administrativa (en particular, un contrato administrativo), declarando su incompetencia para entender en instancia originaria.

(13) Fallos 311:2065, consid. 3° y 5°

(14) <http://www.nicholsonycano.com.ar/eng/publications>.

(15) CSJN, Fallos 305:441; 308:2054; 311:489 y 2725; 312:389 y 1882; 313:98 y 551; 317:746; 320:2567; 323:702 y 1110, entre otros. También se aplicó esta jurisprudencia en la reciente causa "Machuca, Roque Jacinto y otro c. Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", M. 855. XXXIX, del 27/5/2004, Fallos: 327:1786.

De diferente modo no cabe la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de la distinta vecindad o de extranjería —art. 117, Constitución Nacional—, frente a reclamos resarcitorios dirigidos contra la Nación, un Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciertas empresas, por lesión de bienes individuales como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente —en el caso debido al vertido de residuos tóxicos peligrosos en cursos de la Cuenca Matanza-Riachuelo—, al no verificarse el recaudo de “causa civil” exigido por el art. 24, inc. 1 del dec. ley 1285/58 (Adla, XVIII-A, 587), ya que el daño alegado se atribuye a la inactividad u omisión de los demandados en el ejercicio del poder de policía.

9. LA CORTE COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A través de su jurisprudencia en esta materia originaria y exclusiva (“Barreto”, “Mendoza”), así como la recaída en otros tópicos (“Itzcovich”, “Verbitsky”), la Corte Suprema en su actual integración ha puesto énfasis en su rol de Tribunal Constitucional, o de “jurisdicción constitucional” (22), expeliendo de su radio de revisión causas dudosas que no pertenezcan, a su criterio, a este selecto ámbito.

En este sentido es que debe examinarse la lectura más restrictiva que hace el más Alto Tribunal en orden al concepto de “causa civil”.

10. A MODO DE CONCLUSIÓN

La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema en los asuntos concernientes a embajadores extranjeros y los conflictos cuando una provincia sea parte —en causa civil, o cuestiones de medio ambiente entre estados— responde a la necesidad de mantener la paz interior, las buenas relaciones entre los sujetos de derecho internacional y un ambiente sano y equilibrado en todo el territorio de la Nación.

CAPITULO IV.1

ACCIÓN DE AMPARO CLÁSICO O INDIVIDUAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Génesis del amparo. — 3. El derecho público provincial y la acción de amparo. a) Santa Fe. b) Entre Ríos. c) Santiago del Estero. d) Mendoza. e) Chaco. f) Provincia de Buenos Aires. g) Ciudad de Buenos Aires. — 4. Regulación nacional. Etapas. a) Etapa pretoriana (1957-1958 hasta 1966). b) Etapa del amparo reglamentado legislativamente (1966 hasta 1994). c) Etapa del amparo constitucionalizado. — 5. Derechos protegidos en la acción de amparo clásico o individual. — 6. Clases o tipo de amparo. a) Amparo impositivo. b) Amparo por mora de la administración. c) Amparo electoral. d) Amparo sindical. e) Amparo aduanero. f) Amparo por mora previsional. g) Amparo ambiental. h) Amparo interamericano. — 7. Fundamento del amparo. — 8. Operatividad del amparo. — 9. El tema de la legitimación. — 10. Requisitos de admisibilidad. a) Conducta lesiva actual o inminente. b) Evidencia de la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. c) Subsidiaridad del amparo. — 11. El amparo como un procedimiento interdictal. — 12. Los actos demandados fuera de plazo. a) Distintas posturas. a.1) Posición a favor del plazo de caducidad. a.2) Posición contraria. b) Nuestra posición. — 13. El amparo contra actos del Poder Judicial. a) Solución en el derecho comparo. b) Regulación en las provincias. c) Doctrina. c.1) Tesis negatoria. c.2) Tesis positiva. c.3) Nuestra posición. d) Posturas adoptadas por los distintos proyectos de reglamentación del amparo. e) Análisis jurisprudencial. e.1) “Federación Judicial Argentina, Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy y otros”. e.2) “Soler Leopoldo s/ acción de amparo”. e.3) “Miró Héctor D. s/ acción de amparo”. e.4) “Ibarra Absalón s/ recurso de amparo”. 14. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la primera parte de la Constitución Nacional tenemos las declaraciones, los derechos y libertades, los principios, y las garantías. Consideramos a estas últimas como la herramienta o el móvil para proteger todos los anteriores, si tenemos en cuenta que sin las garantías, los derechos podrían llegar a ser no cumplidos porque no tendrían protección ante los tribunales de justicia.

Dentro de las garantías, tenemos la garantía de las garantías y ésta es el amparo, que tutela un sinnúmero de derechos del individuo (excepto la libertad física, pues ella está protegida por el habeas corpus).

(22) V. CARNOTA, WALTER F., “La nueva fisonomía del control de constitucionalidad argentino”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 6, México, julio-diciembre de 2006, p. 157.

especial, en cuanto traduzca el crédito que merece la administración de justicia general, sea expresa y esté convalidada por la Embajada respectiva (16).

La prórroga de la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema sólo es admisible en favor de la jurisdicción provincial o arbitral, si por ella optaron las partes expresa o tácitamente, pero no respecto de los tribunales inferiores de la Nación, ni de los tribunales foráneos (17).

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA

La jurisdicción originaria y exclusiva que los arts. 100 (actual 116) y 101 (actual 117) de la Constitución Nacional confieren a la Corte Suprema presuppone la existencia de una causa o sea de un concreto conflicto de intereses, presupuesto que no concurre en el caso, en el que se pretende una declaración general acerca de la invalidez constitucional del estado de sitio vigente en la totalidad del territorio de la República. Dicha declaración, además, es por completo ajena a las facultades de superintendencia que posee el Tribunal (18).

Además tiene requisitos:

Subjetivo: Sólo procede en razón de las personas: provincia, Estado o ciudadano extranjero.

Objetivos: Se une el requisito de que el litigio asuma el carácter de "causa civil", calificación atribuida a los casos en que están en juego disposiciones de derecho común, o sea el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional (19).

Limitado: Exclusiva e insusceptible de extenderse, más allá de lo establecido por el art. 117 de la CN.

6. CASOS EN QUE NO PROCEDE

Los recursos de habeas corpus son ajenos a la competencia originaria de la Corte Suprema, reglada por los arts. 100 (actual 116) y 101 (actual 117) de la Constitución Nacional, que no contemplan la posibilidad de intervenir —en forma originaria y exclusiva— en tales supuestos. La norma del art. 20 de la ley 48, que asigna al Tribunal competencia para conocer en forma originaria

(16) CSJN *in re*: "Garde de Bouquet, María Mercedes Guillermina Clara c. Letelier Saavedra, Ricardo". 1/1/1960. Fallos: 246:160.

(17) CSJN *in re*: Dirección Nacional de Vialidad. 1/1/1971. Fallos: 280:62.

(18) CSJN *in re*: "Cichello, Carlos Raúl Guillermo". 1/1/1982. Fallos: 304:428.

(19) CSJN *in re*: "Barreto Alberto Damián y otra c. Buenos Aires Provincia de y otro s/ daños y perjuicios". Fallos: 329:759, del 21/3/2006.

en tales recursos, debe interpretarse como aplicable sólo a los casos que puedan subsumirse en el art. 101 (actual 117) de la Constitución Nacional, pues no es dable al Congreso alterar los límites que a dicha jurisdicción asigna la Carta Fundamental (20).

7. RELACIÓN CON LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Con la incorporación de su status autónomo o *cuasi* provincial, deberá coordinarse el art. 129 con los arts. 116 y 117, para interpretar si la situación de no estar citada la Ciudad de Buenos Aires es un hecho casual o causal.

En principio, la falta de previsión del legislador o del constituyente no se presupone, esto es algo de inveterado valor y de seguimiento por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia (21), es decir, que no fue casual sin causal.

Luego tenemos que tener en cuenta que cualquier ampliación violentaría el espíritu del último artículo citado; de hecho el art. 129 no introduce ningún elemento para considerar una ampliación constitucional.

8. DERECHOS AMBIENTALES

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo de fecha 20/6/2006, dictado en la causa "Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros" (LA LEY, 2006-D, 281- Fallos:), en ejercicio de facultades ordenatorias e instructorias previstas en el art. 32 de la ley 25.675 (Adla, LXIII-A, 4), distingue las pretensiones que son de su competencia originaria y exclusiva de aquellas que no lo son. De una parte, considera que "la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva —en el caso, debido al vertido de residuos tóxicos y peligrosos en cursos de la Cuenca Matanza Riachuelo— es de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —art. 117, Constitución Nacional—, frente al carácter federal de la materia en debate —art. 7º, ley 25.675 (Adla, LXIII-A, 4)—, si se ha demandado en forma conjunta entre otros sujetos a la Nación y a un Estado provincial, ante la necesidad de conciliar el privilegio del fuero federal que corresponde al primero con la condición de aforada a la jurisdicción originaria que ostenta la segunda".

(20) CSJN *in re*: "Fuentes, Jorge Henoc. Bucco de De Breuil, Irene Beatriz". 1/1/1983. Fallos: 305: 1931, 2281.

(21) En sentido concordante, ver CSJN, "Dirección General Impositiva", sentencia del 16 de mayo de 2000, Fallos: 323:1201. Ver asimismo y en el cotejo de diversas posturas, ABALOS, MARÍA GABRIELA, "La Ciudad de Buenos Aires luego de la Reforma de 1994: ¿Nuevo sujeto del Federalismo Argentino?", en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y otro (Coordinadores), *Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*, Buenos Aires, 2001, p. 19.

... el amparo es la pretensión formal que se interpone contra el Estado (o cualquier particular) para que por sus órganos jurisdiccionales se depare tutela a una pretensión material mediante vía sumaria y expeditiva" (1).

Podemos considerar dicha acción como un instrumento o medio en virtud del cual se pone en ejercicio la garantía de protección judicial de los derechos básicos previstos implícita o explícitamente en las constituciones liberales.

Pero si consideramos al amparo como un derecho constitucional en sí mismo, presenta entonces, una doble característica siendo un derecho fundamental constitucional y a su vez una acción al servicio de otros derechos y garantías fundamentales (2).

Cuando se reconoce al amparo como un derecho constitucional, goza como tal de las mismas garantías y calificaciones que los demás derechos. Y como tal, si el amparo es y se reconoce como un derecho en sí mismo, tiene autonomía sin necesidad de vincularlo a otros derechos y garantías. A su vez, inviste como derecho de idénticas calidades y condiciones que el "acceso a la jurisdicción".

Para conocerlo más profundamente, será necesario indagar en sus orígenes, sus elementos, en su análisis con el derecho comparado, su situación actual y su papel en el futuro.

2. GÉNESIS DEL AMPARO

El amparo tuvo su origen en México; si bien la Constitución de 1824 no lo menciona expresamente, el art. 137 autoriza a reclamar directamente a la Corte Suprema de Justicia por las infracciones a la ley suprema (3).

Las influencias del constitucionalismo norteamericano, tanto de manera directa como a través de la obra de Alexis de Tocqueville "*De la démocratie en Amérique*" (cuyos dos primeros volúmenes vieron la luz en 1835) repercutieron sobre Manuel Crecencio Rejón y su Constitución para Yucatán de 1841, y como jalones posteriores, pueden mencionarse el Acta de reformas de 1847, inspirada por Manuel Otero, la Constitución del 5 de febrero de 1857 y la ley sobre la materia de 30 de enero de 1869.

Posteriormente es recogido en los arts. 103 y 107 de la Constitución de 1917. De México, pasó a diversas legislaciones del centro y sur de América como ser: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-

(1) BIDART CAMPOS, GERMÁN, *Derecho de Amparo*. Buenos Aires, 1961.

(2) Así lo sostenía Ekmekdjian.

(3) De todos modos, la norma hacía una referencia a la ley reglamentaria, que nunca se expidió. Ver CHAVES CASTILLO, RAÚL, *Juicio de Amparo*, México, 1994, p. 21.

mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela. Del mismo modo en Brasil pero con la denominación de "*Mandato de segurança*".

También tuvo su regulación en las constituciones españolas de 1931 y de 1978.

3. EL DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y LA ACCIÓN DE AMPARO

a) Santa Fe

Esta provincia tiene el honor de haber sido la primera en incorporar el amparo en su Constitución de 1921. En su artículo 17 y en la vigente de 1962, art. 17, estableció el que se denominó "un recurso jurisdiccional de amparo".

Más tarde este instituto fue ampliado por la ley 2494 del año 1935 abarcando los derechos y garantías establecidos en la constitución.

b) Entre Ríos

La Constitución de Entre Ríos de 1933, todavía vigente, estableció en el art. 26:

"...Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés deba ejecutarse el acto o que sufre perjuicio material, moral o político, por la falta de cumplimiento del deber, puede demandar ante los tribunales su ejecución inmediata y el tribunal, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un mandamiento de ejecución";

En su art. 27, estipula que:

"...Si un funcionario o corporación pública de carácter administrativo, ejecutase actos que le fueran expresamente prohibidos por las leyes u ordenanzas, el perjudicado podrá requerir de los tribunales, por procedimiento sumario, un mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o corporación..."

c) Santiago del Estero

Por extensión del habeas corpus, el art. 22 de la Constitución de 1939 aludía a la protección de algunos derechos individuales establecidos en la Constitución Nacional o Provincial.

d) Mendoza

La Constitución de Mendoza de 1949 reguló el recurso de amparo en el art. 33 para ciertos derechos como ser: políticos, de prensa, trabajar, enseñar, permanecer, transitar, o salir del territorio provincial.

219

e) Chaco

El amparo aparece en la Constitución del año 1957 legislado juntamente con el habeas corpus. El art. 19 dispuso un amparo especial para trabajadores y art. 22 los mandamientos de ejecución y prohibición.

f) Provincia de Buenos Aires

El Poder Ejecutivo provincial realizó un proyecto de ley en el año 1964 con sus modificaciones en 1965, que se convirtió en la ley 7166, fuente de la ley nacional 16986.

Actualmente, el amparo se encuentra regulado en el inc. 2 del art. 20 de la Constitución Provincial:

"La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de esta garantía sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos..."

g) Ciudad de Buenos Aires

Con una regulación muy de avanzada se encuentra regulada en su Constitución en el art. 14:

"Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se

ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia del usuario o del consumidor.

El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia.

El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas.

Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva..."

4. REGULACIÓN NACIONAL. ETAPAS

A nivel nacional la regulación del amparo se dividen en tres claras etapas: 1) *Etapa pretoriana* desde 1957-1958 hasta 1966; 2) *Etapa del amparo reglamentado legislativamente*, desde 1966 hasta 1994 y 3) *Etapa del amparo constitucionalizado* desde 1994 hasta la actualidad.

a) Etapa pretoriana (1957-1958 hasta 1966)

Como es sabido, la acción de amparo surge entre nosotros como "creación pretoriana" o de derecho judicial, primero con el caso "Angel Siri" (4) del año 1957, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que "basta la comprobación inmediata de que una garantía constitucional se halla restringida para que surja la necesidad de que aquella sea restablecida por los jueces en su integridad, aun en ausencia de una ley que la reglamente".

Luego con el precedente "Samuel Kot" (5), de 1958, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sienta un principio en virtud del cual no es relevante distinguir si la restricción ilegítima proviene de una autoridad pública o de actos de particulares para la procedencia de la acción de amparo. A dichos casos, los sucedieron otros tantos de manera que surgió entre los doctrinarios el debate por la necesidad de reglamentación legislativa del amparo.

b) Etapa del amparo reglamentado legislativamente (1966 hasta 1994)

La ley 16.986 consagró la acción de amparo contra actos de autoridad pública en el año 1966, para dos años más tarde el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.544) incluir al amparo contra otros particulares.

(4) LA LEY, 89-531, Fallos: 239:459.

(5) LA LEY, 92-632, Fallos: 241:291.

- Art. 1º de la ley 16.986:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el "habeas corpus".

- El art. 321 del CPCCN, regula el amparo contra particulares o proceso sumarísimo:

Será aplicable el procedimiento establecido en el art. 498:

1) A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de pesos cinco mil (\$ 5000).

2) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que esta destinada esta vía acelerada de protección...".

- Art. 498 Trámite:

En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si correspondiese que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido por el procedimiento ordinario, con estas modificaciones:

1) Con la demanda y la contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental.

2) No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvencción.

3) Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que será de cinco días.

4) Contestada la demanda se procederá conforme al artículo 359. La audiencia prevista en el artículo 360 deberá ser señalada dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

5) No procederá la presentación de alegatos.

6) Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que deneguen o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en rela-

ción, en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo.

A pesar de existir posiciones encontradas respecto de la reglamentación de la acción; la misma fue incorporada por la ley 16.986 de 1966. Dicha ley fue altamente cuestionada tanto desde el punto de vista procesal como por sus contenidos de fondo. En lo que respecta al primer aspecto, la crítica se basó en el polémico origen de la ley, ya que surgió de un gobierno de facto. De todas maneras no está de más aclarar que dicha ley rige en la actualidad siempre que no contrarie el art. 43 de la C.N. En referencia a las críticas presentadas respecto de su articulado en lo sustantivo, no consideramos relevante el análisis exhaustivo de cada una de sus cláusulas. Sí cabe aclarar la existencia de un sector doctrinario que considera innecesario reglamentar la acción, especialmente a partir de su incorporación a nuestra Constitución (6).

c) Etapa del amparo constitucionalizado

Los constituyentes de 1994 consagraron de modo expreso en el art. 43 del nuevo texto constitucional lo que hasta entonces era la garantía implícita del amparo (que sólo contaba con la recepción legal referida precedentemente).

- Art. 43 de la Constitución Nacional:

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a prever informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

(6) VALLEFIN, CARLOS. JA, 1997-II-1063.

Como se puede visualizar, allí se receptan varias clases o tipos de amparos:

- a) el amparo individual o clásico, en su primer párrafo;
- b) el novedoso instituto del amparo colectivo, en el segundo;
- c) el amparo especializado de la acción de "habeas data", en el tercero (amén de la incorporación del "habeas corpus" en el cuarto).

Los puntos a destacar como innovadores son el carácter *rápido y expedito* de la acción, su procedencia ante la ausencia de una vía judicial más idónea y frente a conductas emanadas de autoridad pública y de particulares, se amplía la tutela protegiendo no sólo los derechos constitucionales sino también los incluidos en tratados o leyes, se consagra la existencia del amparo colectivo y se ensancha la franja de legitimados, autorizando a demandar al afectado, al Defensor del Pueblo y a las respectivas asociaciones debidamente registradas.

5. DERECHOS TUTELADOS EN EL AMPARO CLÁSICO O INDIVIDUAL

La ley impone la existencia de un agravio referido a los derechos reconocidos en la Constitución, con excepción de la libertad física tutelada por el "habeas corpus", ya sea de manera explícita o implícita. El art. 43 de nuestra Constitución introducido en virtud de la reforma de 1994, extiende esta protección a los derechos amparados por los tratados y las leyes. Esto significa seguir el concepto clásico de Hauriou: los derechos de la Constitución son principios enunciados en conceptos mínimos de contenido indeterminado, por lo que es el legislador quien los integra y desenvuelve. Toda fuente de derechos humanos o constitucionales merece la protección de la acción de amparo. Es la tesis de la doctrina generalizada.

La enumeración de los derechos protegidos por el amparo se ve desplegado a lo largo de toda la primera parte de la Constitución (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, etc.), mientras que los implícitos, se deducen del art. 33 de dicha Constitución, que dice: *"las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno"*.

En virtud de dichas disposiciones, surgen varias posturas doctrinarias respecto a la delimitación del área de derechos protegidos.

La tesis restrictiva (7) exceptúa del amparo a los derechos patrimoniales, los cuales ve suficientemente protegidos por la legislación ordinaria. Consi-

(7) SANCHEZ VIAMONTE, *Manual de derecho constitucional*, Buenos Aires, 1959.

dera entonces que el proceso de amparo procedería únicamente respecto de *derechos constitucionales relativos a la libertad*.

Posteriormente, se produjo una apertura con relación a la tesis restrictiva, que constituye una postura intermedia, la cual permite el amparo para proteger todos los derechos constitucionales, pero lo inhabilita para la protección de los derechos mediatos o indirectamente constitucionales.

Finalmente, los autores proyectan la protección a otros derechos además de los específicamente constitucionales. Se entiende que no hay derecho que no tenga su fundamento mediatos en la Constitución a pesar de encontrarse directamente regido por el derecho común. De esta manera surge la tesis amplia ya que cualquier trasgresión a una ley es reprobable en algún punto por la Constitución (8). En concordancia con esta línea de pensamiento, Bidart Campos sostiene la aplicación de la acción incluso para aquellos casos en los cuales el derecho invocado no derive directamente de la Constitución Nacional, inclusive en aquellas circunstancias en que la lentitud pueda frustrar la idoneidad de la sentencia. Este criterio haría del amparo una suerte de medio de defensa de la legalidad en un sentido general (9).

6. TIPOS O CLASES DE AMPARO

Argentina puede jactarse de una gran variedad de tipos de amparo, que la singularizan en el concierto del derecho comparado, según la investigación que sobre el punto ha realizado el jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor (10).

a) Amparo Impositivo, Ley 11.683 (t. o. 1978, Ley 21.858)

Art. 164. — La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la D.G.I., o de la Administración General de Aduanas, podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos.

Art. 165. — El Tribunal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del funcionario a cargo de la D.G.I. o de la Administración General de Aduanas que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar. Contestado el requerimien-

(8) CARRÍO, GENARO, *Algunos aspectos del recurso de amparo*, Buenos Aires, 1959.

(9) BIDART CAMPOS, *Derecho de Amparo*, Buenos Aires, 1961.

(10) Ver FERRER MAC GREGOR, EDUARDO, "Breves notas sobre el amparo iberoamericano (desde el derecho procesal constitucional contemporáneo)", en VALADÉS, DIEGO y CARDONELL, MIGUEL (Coordinadores), *El Estado Constitucional Contemporáneo*, México, 2006, t. 2, p. 527. El citado autor refiere que en nuestro país se da "una variedad de tipos de amparo sin parangón en Iberoamérica". Idem.

222

to o vencido el plazo para hacerlo, podrá el Tribunal resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.

El Vocal Instructor deberá sustanciar los trámites previstos en la primera parte del presente artículo dentro de los tres (3) días de recibidos los autos, debiendo el Secretario dejar constancia de su recepción y dando cuenta inmediata a aquél.

Cumplimentados los mismos, elevará inmediatamente los autos a la sala, la que procederá al dictado de las medidas para mejor proveer que estime oportunas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la elevatoria, que se notificará a las partes.

Las resoluciones sobre la cuestión serán dictados prescindiendo del llamamiento de autos y dentro de los cinco (5) días de haber sido elevados los autos por el Vocal Instructor o de que la causa haya quedado en estado, en su caso.

b) Amparo por mora de la Administración - Régimen Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19.549

Art. 28. — El que fuere parte en un expediente administrativo, podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijado y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente quien en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

c) Amparo electoral - Código Electoral Nacional, Ley 19.945

Art. 10. — Amparo del Elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Art. 11. — Retención indebida de documento cívico. El elector también puede pedir amparo al juez electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.

Art. 129. — Negativa o demora en la acción de amparo. Se impondrá prisión de tres meses a dos años al funcionario que no diere trámite a la acción de amparo prevista en los artículos 10 y 11 o no la resolviera dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta e igual pena al que desobedeciere las órdenes impartidas al respecto por dicho funcionario.

Procedimiento especial en la acción de amparo al elector. Sustanciación.

Art. 147. — Al efecto de sustanciará las acciones de amparo a que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley, los funcionarios y magistrados mencionados en los mismos resolverán inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplirán sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario, y en su caso serán comunicadas de inmediato al juez electoral que corresponda. La jurisdicción de los magistrados provinciales será concurrente, no excluyente, de la de sus pares nacionales. A este fin los jueces federales o nacionales de primera instancia y los de paz mantendrán abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral. Los jueces electorales podrán asimismo destacar el día de elección, dentro de su distrito, funcionarios del juzgado, o designados ad hoc, para transmitir las órdenes que dicten y velar por su cumplimiento.

Los jueces electorales a ese fin deberán preferir a los jueces federales de sección, magistrados provinciales y funcionarios de la justicia federal y provincial.

d) Amparo Sindical - Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores (11)

Art. 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga si correspondiere el cese inmediato del comportamiento antisindical.

e) Amparo Aduanero - Código Aduanero Ley 22.415

Art. 1660. — La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos.

Art. 1161, — 1. El Tribunal Fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del Administrador Nacional de Aduanas que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.

(11) Ver MACHADO, JOSÉ DANIEL, y OJEDA, RAÚL HORACIO, *Tutela Sindical (Estabilidad del Representante Gremial)*, Buenos Aires y Santa Fe, 2006.

223

2. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo podrá el Tribunal Fiscal resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente.

f) Amparo por mora previsional. Ley 24.655.

Art. 2°. — Los juzgados creados por la presente serán competentes en (Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social): (...) d) El amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19.549, modificada por la ley 21.686, en materia de Seguridad Social.

g) Amparo ambiental (12)

Art. 30, ley 25.675. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

h) Amparo interamericano

El art. 25, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos (o "Pacto de San José de Costa Rica"), hoy con jerarquía constitucional en los términos del art. 75.22 CN dispone que "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales correspondientes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

7. FUNDAMENTOS DEL AMPARO

El amparo surge como complemento necesario de los derechos establecidos por nuestra Constitución Nacional, para su eficaz funcionamiento y

(12) Claro está que habrá que distinguir los supuestos individuales de los colectivos, según la clase de daño que se irroge. Ver MORELLO, AUGUSTO M. y CAFFERATTA, NÉSTOR, *Visión procesal de las cuestiones ambientales*, Buenos Aires y Santa Fe, 2005.

vigencia. Las constituciones liberales consagran y declaran todo tipo de derechos pero si no existieran garantías para poder evitar efectivamente su violación, su mera inclusión en dichos instrumentos resultaría superflua y decorativa (13). En consecuencia, no es esencial determinar el origen de las conductas que restrinjan derechos fundamentales de las personas, sino dichos derechos en sí mismos, para lograr su protección.

8. OPERATIVIDAD DEL AMPARO

La reglamentación de la acción a través de una ley que claramente determine los casos de procedencia ha sido insistido y postulado, dado que no se considera adecuado que sean los jueces los encargados de dicha diferenciación, por razones de seguridad jurídica y orden público.

Existe una parte de la doctrina que sostiene que es imprescindible la reglamentación de todos los aspectos de la norma, como por ejemplo Rodolfo Barra, que específicamente dice que el Congreso debería rápidamente reglamentar el art. 43 de la CN, con una nueva ley sobre amparo.

Otra importante corriente doctrinaria considera que la norma constitucional que prescribe la garantía del amparo es operativa y, como consecuencia no nace de ella la necesidad de establecer, por vía de ley, un mayor detalle acerca de los caracteres y las condiciones de procedencia de la acción. Estiman entonces estos autores que la reglamentación solo sería necesaria desde el punto de vista formal, es decir, para establecer el procedimiento legal para su interposición; pero no para ampliar las condiciones de fondo que hacen a su existencia.

Se entiende que la protección constitucional es más que suficiente y por lo tanto cualquier ley que la reglamente implicaría una forma de restricción. Esta postura otorga una vital participación a los jueces ya que considera que deben ser ellos quienes decidan, caso por caso, qué conductas verdaderamente representan lesiones manifiestas respecto de derechos y cuáles mandan un mayor debate (14).

Por lo tanto, el texto del actual art. 43 de la CN debe entenderse como operativo y a raíz de ello, la reglamentación legal será, con toda probabilidad restrictiva y reiterará las consecuencias que tuvo en su momento la sanción de la ley de facto 16.986 frente a las pautas establecidas por los casos "Siri" y "Kot". Esta es la opinión del jurista Carlos E. Colautti, que además señala, que la abundante jurisprudencia sobre el amparo y su permanente evolución hacen innecesaria su reglamentación legal, siendo tarea de los abogados profundizar nuevas vías para su mejor implementación (15).

(13) ROBREDO, *La acción de amparo y la reciente ley 16.986*. LA LEY, 124-1291/1297, octubre-diciembre de 1966.

(14) OBARRIO, nota al fallo "Iamip Medisur S.A."

(15) COLAUTTI, CARLOS E., "Incógnita de la acción de amparo en la reforma constitucional". LA LEY, del 29/09/1998.

9. EL TEMA DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA

La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el art. 1° de la ley 16986. Podrá también ser interpuesta, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien público (art. 5° de la ley citada).

La legitimación ha sido ampliada como consecuencia natural de las nuevas formas de convivencia. La elección de vivir en concentraciones urbanas, es una característica de nuestro tiempo que ha dado especial relevancia a los derechos de incidencia colectiva. Por ello hoy en día, en numerosos casos las demandas exceden el marco del mero interés individual. Y es precisamente en la acción de amparo donde la reforma de 1994 ha indicado y aceptado con mayor claridad esta realidad.

Cabe indicar que a partir de la reforma del año 1994, el art. 43 de la CN posibilitó la ampliación de la legitimación en los casos mencionados en el segundo párrafo del mentado artículo, con lo cual pueden iniciar la acción tanto el afectado, como el Defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines; el tema escabroso y discutido en la doctrina y jurisprudencia, se manifiesta en cuanto a las asociaciones, si deben estas estar registradas o no para poder accionar. Y bien lo dice el Dr. Colautti, el problema no radicaré en averiguar si las asociaciones tienen o no legitimación, sino en la extensión de los efectos de la sentencia y el mantenimiento de los principios de su efecto entre partes y para el caso concreto.

Una vez analizado el tema de la legitimación para iniciar la acción, a que se refiere el art. 43 de la Constitución, cabe adentrarnos en la cuestión del concepto de "afectado". Para referirnos a este tema, nos será muy útil tomar la opinión del Juez Scalia en torno al *standing*. Básicamente, se concibe la legitimación como correlato de la capacidad otorgada por el ordenamiento, para lograr que un sujeto de derecho obtenga jurisdiccionalmente prestaciones o abstenciones de otros.

El concepto de *standing*, obliga a pensar en tres elementos esenciales que lo integran: la existencia de daño, la causalidad y la reparabilidad o posibilidad de reparar el daño. Ahora bien, cabe hacer la salvedad que la pertenencia de la noción de *standing* a otro sistema, como es el norteamericano, hace importante comenzar la explicación a partir del caso "Lujan", un fallo trascendente en la materia.

En el caso de las acciones colectivas, por medio de las que el Congreso "otorga" *standing* a un número muy general o amplio de accionantes, existe en una variedad de contextos.

La opinión de Scalia se basa en que el recurrente debe demostrar que ha sufrido un perjuicio real y concreto, acreditando el interés personal en el resultado de la controversia, el nexo entre la conducta ilegítima y el daño,

pero asimismo, demostrando que la eventual decisión reparará el daño. En el caso norteamericano "Lujan v. Defensores de la Vida Silvestre" del año 1992, los demandantes llevaron a la Corte a interpretar la extensión de la protección discernida por la ley de especies en peligro de 1973, respecto de las actividades de las agencias, más allá de los límites de los EE.UU., incluso en alta mar. Constituían los actores un grupo interesado en cuestiones ecológicas y dos de sus miembros se consideraron legitimados en virtud de haber visitado países extranjeros en los que EE.UU., había radicado proyectos industriales, que ponían en peligro los hábitats de distintas especies; sosteniendo que volverían a ellos en algún momento indeterminado del futuro.

Finalmente, el voto concluye, declarando inconstitucionales las normas de acción colectiva, en tanto otorgan legitimación a cualquier ciudadano. El voto da por sentado, como doctrina constitucional, el examen de los tres puntos necesarios de la legitimación: perjuicio de hecho, concreto, particularizado y actual o inminente; además exige que el daño surja de alguna conducta u omisión de la demandada y por último que el perjuicio sea susceptible de ser resarcido mediante sentencia de Tribunal.

Ante la amplia gama de legitimados respecto de este tipo de acciones de incidencia colectiva, surge la problemática de la extensión de los efectos de las sentencias adoptadas respecto de estas cuestiones a personas que no revisten el carácter de *parte* del proceso que las origina. De esta manera, se presenta la necesidad de resguardar los derechos de aquellos que pudieran eventualmente ser afectados, al ser alcanzados por los efectos de sentencias en cuyo proceso no han participado. Consideramos que la acción de amparo aparece como la única opción legal para lograr la mencionada protección, no existiendo otra vía más adecuada.

10. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

a) Conducta lesiva actual o inminente

Tanto la legislación como las pautas constitucionales son claras al condicionar la admisibilidad de la acción de amparo a la existencia de una conducta de comisión u omisión que "en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta ciertos derechos constitucionales".

Vemos entonces la exigencia de que la lesión sea *actual*. El amparo no resulta viable para juzgar hechos pasados. La conducta lesiva, ya sea acción u omisión, debe tener vigencia al tramitarse la acción; incluso la amenaza debe ser real y no hipotética. De esta manera se intenta cubrir tanto la amenaza como la lesión, sea parcial o total, a uno o más. El acto o la amenaza pueden producir efectos transitorios y permanentes, sin embargo para que proceda el amparo la presencia deberá ser indefectiblemente actual. Cabe aclarar que la alegación y demostración del peligro actual o inminente de daño corre a cargo de quien promueve el amparo.

225

Asimismo, surge doctrinariamente la necesidad de que el perjuicio, resultante de la lesión sea *real, efectivo, tangible, concreto e ineludible* (16). En consecuencia, el daño que se busca reparar debe ser cierto.

Ahora bien, debemos examinar qué ocurre con la otra posibilidad además de "actualidad", es decir, lo "inminente" que marca el art. 43 de la CN. La acción de amparo, pues, atiende también al pasado exclusivamente en función del presente: lo pretérito sólo interesa en cuanto se prolongue hasta hoy (17).

En principio, el "puro futuro" tampoco interesa en el ámbito del amparo. La Corte Suprema así lo indicó, en el conocido caso: "Cía. de Seguros India c. Caja de Previsión para bancarios" (Fallos: 248:443): si la acción versa sobre hechos del porvenir, no es admisible.

Hay sin embargo otro "futuro", cuya conexión con el presente es íntima y sólida. La denominación mexicana de "actos futuros inminentes", alude, precisamente, a hechos próximos a ejecutarse. Se trata de actos cuya comisión se verificará en un futuro inmediato y que, por ende, pueden interesar al amparo. La amenaza tipifica, en la terminología argentina, esas situaciones (18).

b) Evidencia de la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta

Otro punto de análisis importante es el requisito de que el acto cuestionado sea manifiestamente ilegal o manifiestamente arbitrario para que proceda el amparo. Como resulta claramente de la lectura de ambos textos, legal y constitucional, y de la jurisprudencia, es suficiente la existencia de uno solo de los dos motivos.

La arbitrariedad es una nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación de un derecho. En la medida en que arbitrariedad sea identificada con irrazonabilidad e ilegitimidad (es decir, injusticia), se amplía el ámbito de actos u omisiones que pueden ser cuestionados por la acción de amparo. De todas maneras, es evidente que nos encontramos frente a conceptos legales que pueden dar lugar a distintas interpretaciones acerca de su alcance.

Mientras que "ilegalidad" denota un aspecto más objetivo que surge de una norma contraria a los cánones jurídicos o un actuar por parte del Estado o de un particular contrarios a la ley.

Como ya hemos analizado, el amparo procede frente a actos que presenten una ilegalidad o arbitrariedad *manifiesta*. Se hace referencia a vicios que resulten inequívocos, ciertos, ostensibles, notorios, indudables. Quedan excluidas las cuestiones opinables o ambiguas. Consecuentemente, los hechos deben trascender jurídicamente como claras contradicciones al derecho de manera que el juez pueda llegar sin dudas a su conclusión plena y absoluta.

(16) LAZZARINI, JOSÉ LUIS, *El juicio del amparo*, Buenos Aires, 2003.

(17) SAGÜES, NÉSTOR, *Acción de amparo*, 4ª ed., Buenos Aires, 1995.

(18) V. CARNOTA, WALTER, "El derecho a la información en materia previsional", ED, del 1/11/1999.

Surgen dentro de la doctrina dos posturas acerca de la medida en que la arbitrariedad o la ilegalidad deben ser evidentes. Algunos autores optan por la concepción más estricta limitando el amparo para actos que no presentan margen alguno de discusión y se encuentran exceptuados de todo tipo de investigación. Otros mantienen una postura más flexible permitiendo que los actos cuestionados admitan una leve controversia.

La jurisprudencia en general toma como principio básico que la lesión surja de manera clara e inequívoca, que no presente necesidad de debate amplio o prueba, de manera que resulte lo suficientemente evidente como para que el juez pueda captarla a simple vista. Esto implica que se prueba por sí misma. Así, se descartan los casos en los que el uso de los derechos comprometidos y las defensas presentadas requieran un análisis minucioso para su correcta valuación.

c) Subsidiariedad del amparo

El art. 43 nos indica que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Aquí, en primer termino, se termina con el recaudo o exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa (art. 2º, inc. a, de la ley 16.986), porque cuando indica otra vía tan solo hace referencia a la judicial y ni siquiera cita a la administrativa, por lo que se deduce que ninguna acción de amparo requerirá el inicio previo de la pretensión administrativa.

Por otro lado, se da aquí la llamada subsidiariedad del amparo ante las restantes vías judiciales.

Es decir, para que pueda iniciarse un amparo, no debe haber otra vía judicial más idónea para el desarrollo del derecho desprotegido, porque si para dilucidar la acción una vía ordinaria es mas propicia para su esclarecimiento, será esta última y no otra la adecuada.

Aquí lo más importante es el daño irreparable en el peligro en la demora para la viabilidad del amparo, aunque la ordinaria sea más idónea. La irreparabilidad del daño es la respuesta a la problemática de la vía judicial correspondiente.

11. EL AMPARO COMO UN PROCEDIMIENTO INTERDICTAL

El problema parte de la caracterización formal que corresponde y que no admite un proceso controvertido sino un procedimiento "interdictal" y justamente es eso lo que señalan los votos en disidencia en el caso "Kot", que firman Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte (considerando 11), cuando dicen: "Por su naturaleza y sus fines es una especie de interdicto sumarísimo que el juzgador debería instituir y tramitar, sin audiencia de la contraparte, en reemplazo de los procedimientos ordenados por la ley" (19).

(19) <http://www.semanariojuridico.info/nbibliografica/ver/1/1/6>

226

Pero de esta disidencia muy bien fundada, surgen dos puntos fundamentales: que se trata de un "interdicto", esto es, casi una "providencia cautelar" (Calamandrei) y que no debe haber controversia (contraparte) porque no hay en juego derechos subjetivos contrapuestos o adversariales sino que el fin del arbitrio es el restablecimiento del orden jurídico alterado por el acto o hecho lesivo.

Esta es la tesis que surge del art. 8° de la ley 16896, pues en él se dispone sólo que debe requerirse al autor del acto o hecho lesivo (según sea oficial o particular) un "informe"; no convocarlo como "parte" o sea con todos los derechos formales que corresponden a los sujetos de la litis en un proceso contencioso. Es decir que, en definitiva, se trata de un proceso unilateral como lo menciona José Luis Lazzarini en la 2ª edición de su obra "El Juicio de Amparo" (20).

Pero hoy vemos que no sólo es un proceso netamente contencioso, donde el informe circunstanciado que deberá presentar la contraparte (según el art. 8 de la ley 16.986) es una verdadera contestación de demanda, con amplias peticiones de producción probatoria, sino que además el amparo se ha ordinarizado, transformándose en un verdadera acción ordinaria de conocimiento, donde existen casos cuya sentencia se obtiene luego de 5 o 6 años o más de trámite; lejos está el plazo de 10 (juez de primera instancia) o 15 (Cámara de Apelaciones) días del art. 34 inc. 3. d) del CPCCN o los tres días del art. 11 de la ley 16.986.

Para solucionar este grave deterioro del instituto, debemos volver a sus orígenes donde el amparo era considerado interdictal sumarísimo, rápido y expedito, dejando todo lo que no se pueda resolver de este modo a otro tipo de acción, por mas que el amparo sea siempre mas idóneo (exceptuando el daño irreparable de la otra vía), porque aquí lo idóneo o no es la naturaleza procesal del amparo y volver a los valores que tenía en sus comienzos.

12. LOS ACTOS DEMANDADOS FUERA DE PLAZO

El art. 2° en su inciso e), ley 16.986, dispone que el amparo no es admisible cuando "... la demanda no hubiese sido presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse..." (21).

La ley 16.986 ha establecido un plazo de caducidad de 15 días hábiles que teniendo por objeto otorgar estabilidad a los actos estatales, lo que exige es que su impugnación sobrevenga en cierto tiempo, presuponiéndose que su transcurso los consolida y equivale a resguardar el valor seguridad jurídica.

(20) Buenos Aires, 1987, p. 280, 2° párrafo.

(21) En sentido similar, aunque con mayor precisión ampliando a 30 días el plazo, legisla el art. 6° del ordenamiento bonaerense.

Se ha justificado la restricción que emplaza el inciso en estudio, con la invocación del mentado valor "seguridad jurídica", la existencia de una especie de consentimiento tácito del afectado, la concepción del amparo con carácter excepcional, hasta el principio de división de poderes. Se pondría en cabeza del amparista la exigencia de obrar con diligencia y celeridad para interponer la acción (22). De lo que es dable interpretar que el plazo de caducidad de 15 días, corre como una suerte de sanción para el legitimado en la pretensión de amparo por su negligencia en demorar la interposición de la acción de amparo.

La inadmisibilidad del amparo interpuesto fuera del plazo establecido en el inc. e del art. 2° de la ley 16.986, provocó en doctrina y jurisprudencia variadas consideraciones y críticas que intentaremos esbozar a continuación.

a) Distintas posturas

En este punto podemos abordar el análisis desde dos posturas bien diferenciadas en doctrina.

a.1) Posición a favor del plazo de caducidad

Una primera postura sería la que se desprende del voto mayoritario del fallo Plenario (23) de la Cámara Nac. Civ. y Com. Fed., en autos "Capizzano v. IOS", que se expresa a través del voto del Dr. De las Carreras. Posición ésta que parte de la nota de expeditividad y de rapidez del amparo, pero concluye que precisamente por tal fisonomía procesal, fijar un plazo para que el interesado lo promueva, so pena de caducidad de la acción, es perfectamente lógico (de lo contrario, resultaría que si el afectado se toma un largo tiempo para introducir el amparo, ello significa que no estaba urgido para plantearlo, y que por ende, no precisaba de una acción expedita y rápida, según la dibuja el mentado art. 43 CN. Podría ir, como se infiere de su propia conducta pausada, a las vías ordinarias) (24).

Se sostiene también que estamos frente a un derecho excepcional que sólo procede en situaciones de imprescindible necesidad. La ley general posterior no deroga la ley anterior especial, salvo que existiere incompatibilidad entre ellas. Que debe existir un plazo para el ejercicio de la acción, ya que el mismo no puede quedar librado a la discrecionalidad de los jueces y que por lo tanto, al no estar vedado en la Constitución, en la especie debe aplicarse el plazo de caducidad que contempla la ley 16.986 en su art. 2° inc. e), siempre que no exista otro plazo otorgado por ley (25).

(22) Es dable recordar aquí la doctrina del caso "Saguier", CNCiv., sala D, 19/4/1968, ED, 23-427.

(23) CNFed. Civ. y Com., 6/3/1999, en autos "Capizzano de Galdi, Concepción c. Instituto de Obras Sociales".

(24) Según SAGÜES, NÉSTOR P., *El plazo de caducidad de la ley de amparo ante la Reforma Constitucional*. Buenos Aires, JA, 5/4/2000, N° 6188.

(25) SABSAY, DANIEL A. ob. cit., p. 30.

Sagüés (26) considera que no cabe considerar que la reforma constitucional haya instrumentado un régimen normativo autosuficiente, alérgico a reglamentaciones razonables; el hecho de que el art. 43 sea operativo, no determina que sea hermético. Este autor considera atractiva la posición del voto mayoritario del fallo citado, considerando que no parece absurdo sino coherente con el comprimido y urgente proceso de amparo fijar el referido plazo, precisando que si el afectado dilata la articulación del amparo significa que no estaba apurado para plantearlo.

También se ha entendido, en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal que la ley 16.986 debía seguir aplicándose, en cuanto no se opusiera al art. 43 de la constitución (27), siendo esta postura la que admite la subsistencia actual del art. 2º inc. e) la habitualmente mayoritaria en la experiencia jurisprudencial (28).

a.2) Posición contraria

La postura opuesta es sostenida por el voto en disidencia del Sr. Juez Pérez Delgado, de quien haremos transcripción del resumen que hace Rivas (29) en su comentario al fallo: "el voto minoritario expresó resumidamente:

- a) que la ley 16.986 contiene dispositivos relativos a los presupuestos de admisión de la acción y otro de tipo procedimental;
- b) que el plazo de caducidad está comprendido entre los primeros y no entre los segundos;
- c) que atento el sentido de la reforma constitucional es jurídicamente razonable echar mano de los aspectos procedimentales de la ley 16.986 pero no ocurre lo mismo con los de admisión;
- d) que debe considerarse que el amparo consagra una protección expeditiva y rápida;
- e) que el texto constitucional se basta a sí mismo y proporciona un soporte del que hace a la ley 16.986 de modo que es ajeno a la cuestión considerada, establecer si es posible legislar fijándose un plazo similar al contenido por la ley derogada;
- f) que la inexistencia de un plazo de caducidad expresamente fijado por la ley no significa que el amparo pueda ejercerse en cualquier tiempo pues para ello, el remedio está previsto como expedito y rápido, precisamente para enfrentar lesiones actuales o inminentes".

(26) SAGÜÉS, NÉSTOR P., *El plazo de caducidad de la ley de amparo ante la Reforma Constitucional*, citado.

(27) Conf. SPOTA, ALBERTO A., "Análisis de la acción de amparo en los términos del art. 43", ED, 163-767.

(28) GOZÁINI, OSVALDO A., *El derecho de amparo*, Buenos Aires, 1998, p. 73.

(29) RIVAS, ADOLFO A., "El plazo de caducidad en el amparo", LA LEY, 2000-C, 347.

El voto en disidencia de Pérez Delgado, parte del supuesto de que el art. 43 CN es autosuficiente y por ende, autooperativo: regula los requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción y quiénes se hallan legitimados para actuar en ella; por tanto "se basta a sí mismo" y no tolera agregados de otros requisitos que tengan como presupuesto un diferente régimen constitucional.

A los fundamentos esgrimidos por Pérez Delgado ha adherido Quiroga Lavie (30).

Por su parte, Rivas sostiene que el art. 43 CN cuando normativiza la acción de amparo, puede no ser incompatible con una legislación reglamentaria complementaria de la Ley Suprema, pero entiende que el plazo de caducidad contemplado en el art. 2º inc. e), ley 16.986 pasa a ser inconstitucional al colisionar con la idea de un amparo expedito y rápido, efectivo custodio de los derechos constitucionales.

Desde esta perspectiva el referido inciso implicaría hoy una reglamentación irrazonable (31) del art. 43 constitucional.

También este autor reputa que los condicionamientos de la ley 16.986, en la que en alguna oportunidad ingeniosamente la llamó "ley contra natura", deben ser de interpretación restrictiva y que con el nuevo art. 43 del que no cabe discusión sobre su operatividad, corresponde sostener que ha caído todo lo que pueda obstar a su vigencia plena, inclusive si estuviese en el campo meramente procedimental.

El art. 43 no prevé un plazo de caducidad de la acción de amparo; tampoco se prevé en los Tratados Internacionales que a partir de la Reforma Constitucional de 1994 conforman el "bloque de Constitucionalidad Argentino"; repárese en la inexistencia de este tipo de plazo en la acción de habeas corpus y habeas data respectivamente. Como tampoco el texto constitucional, habilita el arbitrio jurisdiccional para la fijación de límite temporal alguno. En este caso, debe considerarse con criterio absolutamente restrictivo la aplicación de la ley 16.986 subsistente por ser un régimen normativo procesal especial anterior a la norma Constitucional general ulterior; recordando que en materia de amparo, los antecedentes "Siri" y "Kot" nos demuestran que no se precisa regulación positiva para tomar operativa la protección de los derechos individuales.

(30) QUIROGA LAVIE, HUMBERTO, "La violación por tracto sucesivo de los derechos constitucionales y la operatividad del art. 43 CN", LA LEY, 1996-C, 507 y "Actualidad en la Jurisprudencia del Amparo", LA LEY, 1996-E, 1061.

(31) Así los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional consagran la operatividad de los derechos reconocidos en la nuestra Carta Magna, como regla general, sin que sea necesaria una legislación reglamentaria. También el art. 33 cuando se refiere a las garantías emanadas por la Constitución, cabe incluir entre ellas al amparo por ser un instrumento eficaz para concertar con celeridad y el restablecimiento de las libertades constitucionales. Por último, nos remitimos al art. 19, todos dentro de la Constitución Nacional, del cual se desprende que si aceptáramos que solamente son normas jurídicas válidas las que están de acuerdo con la Constitución, todos aquellos actos que no se basaron sobre esas normas no podrían perturbar las libertades constitucionales y si así lo hiciesen se podría restablecer la plena vigencia de la Constitución Nacional declarando la nulidad de tales actos y sus efectos.

La ley 16.986 estableció en su art. 2° amplias restricciones a la acción de amparo, ordenando en su art. 3°, que el juez deba realizar, *ab initio* del proceso, "un juicio de admisibilidad", debiendo éste tener en cuenta las limitaciones establecidas por imperio de los arts. 1° y 2° de la norma referida.

b) Nuestra posición

Es lógico considerar que no hay nadie más interesado en la celeridad de la interposición de la pretensión amparista que el propio titular del derecho que fuera vulnerado, siendo éste quien vive en carne propia el grado de urgencia que ostenta la pretensión procesal en la satisfacción jurisdiccional de tutela, con la patencia que todo ello trae aparejado.

En efecto, nadie duda que el tiempo jurídico debe administrarse con razonabilidad y responsabilidad, del cual no escapa el tiempo referido a la interposición del amparo por su sincronismo con el "principio de actualidad", siendo éste un requisito para su admisibilidad.

En el escenario que se encuentra el legitimado a pretender amparo, a tenor de la importancia y la jerarquía de derechos (en el sentido de su mayor o menor restringibilidad) que se debaten en el amparo, concebido como un instrumento de socorro al sistema procesal, nadie mejor que el afectado para sentir la influencia del tiempo, que como bien señala Couture "el tiempo en el proceso es más caro que el oro, es la justicia".

Con todo ello queremos significar que la acción de amparo no puede ser interpuesta en cualquier momento, sino que siempre deben respetarse sus presupuestos formales para velar por la seguridad jurídica porque nadie se podría considerar seguro de un derecho, que puede ser cuestionado a través de algún amparo.

Pero tampoco estamos a favor de los 15 días establecidos en el art. 2° inc. e) de la ley de amparo, sino de 30 días, teniendo posibilidad de que el juez actúe fuera del plazo cuando la alteración del derecho o la libertad sea de tal magnitud que requiera una solución inmediata y que no haya otra forma de remediarla, aplicando de este modo la operatividad temporal excepcional del amparo. También aceptamos la teoría (con sustento en actual jurisprudencia de la Corte Suprema) que sostiene que el plazo de caducidad renace a partir de la verificación de cada violación en obligaciones de tracto sucesivo, como las salariales.

Con ello estamos ayudando al amparo, para que vuelva a ser una vía excepcional, expedita y rápida, y no lo que es hoy un amparo, un juicio ordinario de conocimiento, con 4 o 5 años para obtener sentencia definitiva.

13. EL AMPARO CONTRA ACTOS DEL PODER JUDICIAL

Consideramos importante para comenzar el desarrollo del tema, partir de un marco legal; el cual está dado por el art. 2° inc. b) de la ley de amparo

que establece la no procedencia de la acción cuando "el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial...".

Debido a la vaguedad de las palabras utilizadas la pregunta se centra en determinar si están incluidos no solamente los actos judiciales de decisión como las sentencias y resoluciones; sino también los actos judiciales de comunicación, que informan sobre las decisiones adoptadas, los actos judiciales de ejecución que procuran el cumplimiento de dichos pronunciamientos y los actos administrativos en su carácter de un poder del Estado.

Por otra parte, al hablar el artículo de "órgano" en general, no se realiza ninguna distinción de instancias o funciones. Es muy probable que la intención del legislador haya sido la de incluir todos aquellos actos de cualquier miembro del Poder Judicial que desempeñe funciones jurisdiccionales.

A pesar de la existencia de dicho inciso, se da una gran controversia especialmente desde el ámbito doctrinario, acerca de la procedencia del amparo contra actos judiciales. Surgen así, tesis totalmente restrictivas que prohíben terminantemente la acción para estos casos; y otras más flexibles que admiten contra ciertos actos judiciales o incluso contra todos ellos.

a) Soluciones en el Derecho Comparado

Cuando se realizan comparaciones de herramientas jurídicas en distintos países es necesario, inicialmente, poner en claro si los conceptos que se manejan son verdaderamente equivalentes y si presentan las mismas características.

En consecuencia, cuando observamos la acción de amparo en el derecho mexicano debemos tener en cuenta que en cierta manera fusiona la vía del amparo con la acción por inconstitucionalidad. Por lo que, a diferencia de nosotros, no posee un recurso de inconstitucionalidad; razón por la cual es natural que se dé el amparo contra actos judiciales.

Por otra parte, el caso de Brasil presenta características similares a las nuestras al tener diferenciados el amparo del control de constitucionalidad. Sin embargo, llegan a otra solución para la problemática, admitiendo el amparo contra actos judiciales en situaciones excepcionales, cuando hay ausencia absoluta de recursos contra los mismos e imposibilidad para su corrección. Una innovación del sistema constitucional español lo configura la posibilidad de articular el recurso de amparo contra actos jurisdiccionales, con arreglo al art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Cabe destacar que el grueso de los amparos españoles se dirige contra sentencias judiciales, por violación al derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24 de la Constitución de 1978 (32).

(32) Ver CARNOTA, WALTER F., "Dos visiones constitucionales divergentes sobre el amparo: los casos argentino y español", en *Cuestiones Constitucionales* (Revista Mexicana de Derecho Constitucional), N° 9, UNAM, México D.F., julio-diciembre de 2003, p. 64.

b) Regulación en las provincias

La postura adoptada por la mayoría de las leyes provinciales, en concordancia con la corriente sentada por la ley 16.986, es la de no aceptar el amparo contra actos emanados del Poder Judicial. Dicha prohibición surge de manera explícita en las leyes 4915 de Córdoba; 2903 de Corrientes; 749 de Formosa; 368 de Misiones; 2596 de San Luis; entre otras.

A modo de excepción cabe destacar la legislación de La Rioja que presenta una postura alternativa. En la Constitución de 1986 habilita el amparo contra cualquier "autoridad" en el art. 28. Más específicamente establece en el art. 380, ap. 2, de la ley 3372 que "si el acto impugnado emanara del Poder Ejecutivo de la provincia o de alguna autoridad judicial, el órgano competente para entender en la acción de amparo, será el Superior Tribunal". Surge del texto con gran claridad la inclusión de los actos emanados del poder judicial dentro de la nomina de actos impugnables por vía de amparo.

c) Doctrina

c.1) Tesis negativa

Entre los autores que consideran improcedente al amparo contra actos judiciales podemos destacar a José Luis Lazzarini (33) y a Armando Emilio Grau (34). Fundan su posición en razones de seguridad jurídica, de orden procesal y de protección a la institución de la cosa juzgada; incluso le adjudican a la admisión de la acción consecuencias de gran magnitud como la perturbación del proceso judicial, la anarquía y el ataque a las bases fundamentales del Estado de derecho.

Para este sector de la doctrina, el proceso jurisdiccional cuenta con un orden preestablecido que permite la revisión específica y ordenada de las decisiones adoptadas y finaliza con una sentencia definitiva llamada cosa juzgada. Todo ello hace a la protección del valor seguridad jurídica. Si se admite que otro juez interrumpa en los procesos judiciales que se sustancian ante otro o analice lo ya resuelto con autoridad de cosa juzgada, se estaría quebrantando el sistema judicial en sí mismo.

Los partidarios de la tesis negatoria consideran que se encuentran previstos dentro de la legislación procesal los medios necesarios para evitar que no quede sin revisar "una sentencia arbitraria, un error o una restricción ilegítima, clara y manifiesta de algún derecho constitucional". No surge en consecuencia la necesidad de recurrir al amparo cuando el propio proceso judicial prevé dentro de su estructura métodos de revisión, siendo significativamente relevante la interpretación jurisprudencial además de la existencia de tribunales revisores.

(33)-Op.cit.

(34) "Improcedencia del amparo contra actos judiciales y políticos", JA, 1961-V-97.

Dicha postura ha recibido amplia recepción en nuestra legislación no solo a través de la ley 16.986, sino también en la ley 7166 de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 3°. Estas normas se suman a la idea de que un juez no interfiera en el obrar de otro. Sin embargo surge de la ambigüedad del término "órgano judicial"; la inclusión o no de los órganos administrativos del Poder Judicial, que no poseen función jurisdiccional.

Otro caso para tener en cuenta es el de las causas judiciales en trámite. Respecto de ellas, las opiniones expuestas tampoco aceptan la procedencia de la acción, considerando que las partes que se sientan agraviadas deben buscar una solución dentro del mismo tribunal competente y no recurriendo a otro.

c.2) Tesis positiva

Existen, sin embargo, otros autores que conciben la aplicación del amparo frente a la lesión de derechos fundamentales causada por actos emanados del Poder Judicial. Entre ellos destacamos a Bartolomé A. Fiorini (35), a Linares Quintana (36) y a Germán J. Bidart Campos (37), entre otros.

Si bien la corriente que acepta la procedencia de la acción posee variantes respecto a qué actos judiciales y qué casos específicos abarca, el fundamento primordial que todos los autores partidarios sostienen es el de la primacía de principios incluidos explícita e implícitamente en la Constitución tales como la libertad y la justicia; frente al valor seguridad que sustenta la corriente negatoria.

Las diferencias más notorias se dan en lo que respecta a cuáles son los actos judiciales que deben ser protegidos por el amparo. Así, Fiorini condena la forma genérica utilizada por la legislación y realiza una distinción entre los actos del proceso que no considera pueden ser abarcados por la acción; y otro tipo de actos como serían los actos administrativos dictados por el Poder Judicial ya sea respecto a sus agentes administrativos o en cuanto a las actividades administrativas del mismo órgano judicial. Según su punto de vista, no se puede tomar una decisión acerca de la procedencia del amparo sin tener en cuenta las distintas clases de actos judiciales y sus características. Por otra parte Carrió y Bidart Campos sostienen posiciones más amplias abarcando también decisiones procesales.

En lo que respecta al tribunal que debe entender en un amparo presentado contra un acto judicial, la doctrina plantea la necesidad de que sea el de alzada pertinente por razones de seguridad jurídica y de respeto a la justicia. Así se evitaría producir un trastorno al orden jurídico provocando un daño mayor que el que se pretende enmendar por la vía del amparo.

(35) "Acción de amparo. Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan", LA LEY, 124-1365.

(36) Acción de amparo, Buenos Aires, 1960.

(37) Derecho de amparo.

230

c.3) Nuestra posición

La ley es clara en su art. 2º, inc. b) cuando establece que no se admitirá el amparo cuando el acto cuestionado provenga de un "órgano del Poder Judicial". La expresión utilizada por el legislador es excesivamente amplia ya que no hace referencia a la naturaleza de los actos que se pretenden excluir. Directamente se descartan todos los actos emanados de cualquier órgano del Poder Judicial, incluso cuando no realicen funciones de carácter jurisdiccional. No se tienen en cuenta las distintas clases de actos judiciales, los cuales poseen características propias a la hora de ser impugnados. De esta manera la prohibición alcanzaría tanto a las decisiones de los Tribunales como a las conductas del Poder Judicial actuando en ejercicio de la función administrativa, sin que en este último caso existan razones de peso para impedir la procedencia del amparo. Esta amplitud es la principal crítica que nosotros encontramos en la norma.

La problemática de la admisión de la acción del amparo contra actos emanados del Poder Judicial no posee en la doctrina de nuestro país una solución única. Como ya hemos desarrollado a lo largo de este capítulo, existen distintas posturas frente a este problema que van desde la negación absoluta hasta la admisión explícita dentro de determinadas condiciones.

Sin embargo, nosotros creemos que deberá realizarse una diferenciación entre los actos del Poder Judicial de carácter jurisdiccional y aquellos emitidos en el ejercicio de funciones administrativas. Para estos últimos consideramos procedente el cuestionamiento por medio del amparo, por ser la vía judicial una revisión de la propia arbitrariedad administrativa del órgano judicial y no ya como órgano jurisdiccional que pudiere alterar la seguridad jurídica. Sin perjuicio que en casos de urgencia y flagrante violación a los derechos por el órgano jurisdiccional especial actúe el amparo contra una sentencia firme, como son los casos jurisprudenciales mencionados *infra*.

d) Posturas adoptadas por los distintos proyectos de reglamentación del amparo

Al buscar información acerca de la procedencia de la acción de amparo contra actos del Poder Judicial nos encontramos con diversos proyectos de ley que a pesar de su falta de actualidad, consideramos importante rescatar por presentar una postura positiva de admisión de la acción, novedosa respecto de la adoptada por la ley 16.986.

El más antiguo de ellos es el proyecto Matienzo. El mismo fue presentado en el año 1934 por el senador José N. Matienzo y establece como objeto de la acción de amparo "la protección de la justicia federal contra todo acto de funcionario nacional o provincial que viole los derechos individuales garantidos por la Constitución de la Nación, aunque dicho acto este autorizado por leyes nacionales o provinciales". Vemos como el proyecto no le da relevancia al origen específico del acto al utilizar la palabra genérica "funcionario". En consecuencia, la procedencia de la acción está dada por la existencia de una violación de derechos por el acto cuestionado sin consideración del órgano estatal del cual fue emanado dicho acto.

Posteriormente, el proyecto Pastor - Belgrano Rawson, determinó que el amparo implicaba la instauración de "un proceso sumario contra la autoridad pública que ejecutase hechos prohibidos por la ley o incumpliera sus deberes". De manera similar, el proyecto Allende, consideraba a la acción un "procedimiento sumario contra la autoridad que impidiera el ejercicio de un derecho declarado en la Constitución Nacional. Ambos proyectos no hacen referencia explícita a la admisión del amparo contra actos del poder judicial, por lo que la misma no queda automáticamente excluida.

En el año 1950, el proyecto Yadarola, dispuso la posibilidad de recurrir a la acción de amparo respecto de todo tipo de actos de autoridad siempre y cuando no fuesen de "carácter estrictamente judicial" y se lesionare o amenazare con lesionar un derecho constitucional. De forma tal que surge una restricción basada en la naturaleza del acto pero no en el órgano estatal que le dio origen.

Dentro de la misma línea surge el proyecto del "Instituto Argentino de Estudios Legislativos". El mismo en sus artículos 1, 2 y 3 comprende entre los actos susceptibles de ser cuestionados por el amparo, aquellos de autoridad o de particulares, incluso los emanados del Poder Judicial en cuyo caso entendía el tribunal de alzada correspondiente. La novedad introducida por este proyecto respecto de los anteriores es la mención expresa respecto de la procedencia del amparo frente a actos judiciales.

Finalmente, incluimos a dos proyectos. Uno de ellos es el número 379/99, presentado por los senadores Menem y Yoma. No realiza una distinción de los actos cuestionables por la vía del amparo, sino que establece como condición de admisibilidad la no existencia de "otras vías judiciales más idóneas para asegurar la rápida y eficaz protección del derecho que se trate, circunstancia que debe ser fundadamente invocada por el accionante y apreciada con criterio amplio por el juez" (art. 2º, inciso A). El otro proyecto, número 1410/98, presentado por el senador Genoud y otros, de manera similar, establece como restricción a la aplicación del amparo la existencia de "otra medida judicial más idónea". Ambos proyectos no delimitan la acción en razón del órgano del cual emana el acto supuestamente violatorio de derechos humanos dado que lo importante no es quien realiza el acto sino proteger a quien resulta afectado. De esta manera optan por dejar a criterio de los jueces la decisión de admisión del amparo para cada acto específico teniendo en cuenta las características y los objetivos de dicha acción y no los limitan como la ley 16.986 en virtud de consideraciones meramente formales como es el hecho de que el acto provenga de un órgano judicial.

e) Análisis de jurisprudencia

e.1) "Federación Judicial Argentina, Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy y otros", expte. 36.632, del 02/03/1993.

La sentencia de segunda instancia es dictada con fecha 2 de marzo del año 1993, en San Salvador de Jujuy.

231

La cuestión se suscita, respecto del amparo interpuesto contra la revisión judicial de resoluciones disciplinarias del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.

El fallo analizado, llega a segunda instancia en virtud de una acción de amparo promovida en contra de resoluciones disciplinarias del Superior Tribunal.

En su voto, la Doctora Castro dijo: Que las resoluciones han sido adoptadas por el Superior Tribunal, en uso de sus facultades propias de superintendencia acordadas por las leyes respectivas (ley 3419, art. 46, inc. 11), las que siendo irrecurribles no pueden ser objeto de revisión por la Cámara pertinente. Que en consecuencia de ello, corresponde declarar la incompetencia de ese Tribunal para entender en la acción de amparo interpuesta.

La Doctora Izquierdo de Jaquet dijo: Que se interpone la acción de amparo en contra de acordadas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en ejercicio de potestades administrativas, por las cuales se aplican sanciones disciplinarias. Que la vocal preopinante, propicia declaración de incompetencia de la Cámara para entender en la acción promovida, por considerar que las resoluciones emanadas del Superior Tribunal adoptadas en uso de sus facultades de superintendencia no pueden ser objeto de revisión por ese Tribunal de segunda instancia. Que en consecuencia, y a los efectos de no incurrir en confusiones, cabe dejar en claro que la cuestión a resolver está referida pura y exclusivamente a la competencia o incompetencia del Tribunal para entender en una acción de amparo. Que dentro de los límites planteados en el tema, la Doctora Izquierdo disiente con la Doctora Castro, exponiendo sus razones. Y bien dice, que las funciones de superintendencia que cumple el Superior Tribunal de Justicia le son otorgadas al mismo por el art. 118, inc. 5 de la Constitución de la provincia y por la ley 3419 (orgánica del Poder Judicial) en su art. 46, y ellas están referidas al desenvolvimiento de la faz administrativa no jurisdiccional. Que en dicho mérito, puede ejercer el control jerárquico de su respectiva organización respecto de los funcionarios integrantes del Poder Judicial y del personal asignado, haciendo efectiva dicha jerarquía mediante sanciones disciplinarias, las que según dispone el reglamento disciplinario del Poder Judicial, son irrecurribles. Que esa subordinación jerárquica comprende estrictamente el aspecto administrativo, pero en cuanto al aspecto funcional, los jueces no están subordinados jerárquicamente, sino funcionalmente. Que tratándose de una decisión administrativa como se ha dicho, entiende la vocal, puede ser susceptible del planteamiento del amparo.

Para ello, la Doctora Izquierdo, se remite y apoya su tesis en la opinión doctrinaria de Néstor Sagüés en su obra "Ley de Amparo, Comentada, Anotada y Concordada", que citando la opinión de Fiorini, considera que el amparo debe ser viable cuando el Poder Judicial actúe en funciones administrativas de superintendencia. Que por todos los fundamentos expuestos, vota en el sentido de que el Tribunal es competente para entender en la acción planteada, debiendo dársele trámite.

El Doctor de los Ríos dijo: Que en cuestiones de amparo, ya se ha decidido que no corresponde ni su tramitación ni su procedencia, cuando se interpone respecto de una decisión adoptada por un órgano del Poder Judicial, y citando nuevamente a Néstor Sagüés, dice que admitirlo, sería introducir una instancia de revisión que imponga desorden en la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto a los autos de referencia, lo que se pretende no es una acción de amparo respecto a una decisión judicial resuelta por el Superior Tribunal de Justicia, sino una decisión administrativa, de carácter disciplinario adoptada por dicho órgano. Por lo que también el Doctor de los Ríos disiente con el primer voto. A su vez, menciona que conforme a la tesis permisiva imperante, ya adoptada en forma unánime por los tribunales del país, cuando se trata de decisiones de carácter administrativo, las mismas son susceptibles de recurso de amparo. Además agrega que la solución surge como razonablemente correcta, ya que el reglamento disciplinario del Poder Judicial dispone como irrecurribles las sanciones impuestas por los órganos colégiados, quedando abierta, por ende, la acción de amparo, que permitirá dilucidar la cuestión planteada. Por todo lo expuesto, considera que el Tribunal es competente para entender en la causa, adhiriendo así, al voto de la Doctora Izquierdo de Jaquet.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de la provincia de Jujuy, resuelve declararse competente para entender en los autos de referencia, y en consecuencia imprimirse el trámite pertinente.

e.2) "Soler, Leopoldos/ acción de amparo", CFed. Mendoza, sala A, expte. 90485, del 21/2/1992

Acción de amparo tendiente a que se levante la medida cautelar que ordena la clausura de un estudio jurídico profesional.

El caso llega a segunda instancia, a raíz de una acción de amparo promovida por el Dr. Soler, por lo que considera un cierre arbitrario, ilegítimo e infundado de su estudio jurídico, con motivo de una medida de clausura dispuesta desde el 10 de Febrero de ese año por el Juez Federal de San Juan en la causa 847. El actor señala que posee su estudio en el mismo edificio que el Dr. López Mengual, contra quien iba dirigida la medida que lo afecta, por lo que él no tiene vinculación alguna con el proceso. Asimismo, indica que ha intentado los remedios judiciales pertinentes, y que a pesar de ello, continúa prolongándose en el tiempo una medida que le ocasiona perjuicios, tanto de carácter moral como patrimonial, en abierta violación al derecho constitucional de trabajar y ejercer libremente su profesión.

La Cámara falla declarando su competencia para entender en la causa y haciendo aplicación supletoria de la ley 16.986 solicita al Juez que ordenó la clausura del estudio donde desempeña su labor el Dr. Soler, que informe a tenor del art. 8 respecto de las razones y alcances de tal medida. A su vez, dispone que por secretaría se constate la clausura denunciada y la ubicación de los estudios jurídicos allí existentes, comprobándose que tal domicilio

232

tiene totalmente clausurado su ingreso. El Juez Federal de San Juan realiza el informe solicitado, indicando que dispuso la clausura del local donde funciona el estudio del Dr. López Mengual, en razón de que podrían encontrarse elementos vinculados con la causa que el mismo investiga. Deja en claro también, que no tenía conocimiento que en el lugar funcionara otro estudio jurídico, considerando que con esa medida no causaría perjuicio, en tanto su titular (el Dr. López Mengual) se encontraba detenido y el reconocimiento del lugar podría efectuarse sin mayor premura. Reconoce también la presentación de los recursos por parte del Dr. Soler, como así también la denegatoria de tales presentaciones.

Luego de identificar como se suceden los hechos, la Cámara resuelve:

I. En primer lugar se analiza la procedencia del recurso de amparo, y en forma particular contra decisiones de un órgano judicial, dejando en claro que, ello constituye un remedio de carácter excepcional, cuando frente a un agravio constitucional, no existen otros remedios idóneos de reparación eficaz. La Cámara para argumentar su posición, cita palabras de la Corte Suprema, en cuanto dice que, "cabe reservar el remedio singular del amparo solo para las diligencias y extremas situaciones, en las que, por carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos fundamentales y que para su apertura se requieren circunstancias de muy definida excepción" (fecha 20/2/1986, Fallos 308:217). También considera que, además de la excepción prevista en el párrafo anterior, está la restricción del art. 2° inc. b) de la ley 16.986, cuando expresa que el amparo será inadmisibile, cuando el acto impugnado emane de un órgano del poder judicial. Límite, que a su vez, ha merecido de la doctrina comentarios desfavorables, que afirman que el amparo es una garantía constitucional innominada o implícita, que no nace de la ley, sino de la constitución y que el legislador podría reglamentar, pero no desvirtuar (conf. Sagiés, "Derecho de Amparo", Ed. Astrea, p. 207), en tanto el tiempo de su tramitación prolongara el agravio, y la solución no será totalmente eficaz (id., Rivas Adolfo A., "El Amparo", Ed. La Rocca, 1987). A su vez, la Cámara declara su competencia para entender en la acción de amparo interpuesta, en virtud de ser el Superior inmediato del órgano judicial autor de la medida atacada.

II. Que resulta de las constancias de autos, que el amparista, en razón de la clausura del ingreso al lugar donde tiene su estudio, se ve privado de ejercer su profesión, violándose lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución. El Tribunal de Alzada, argumenta que debe tenerse presente que el actor no se encuentra vinculado al proceso, y que si bien el letrado procesado tiene en ese mismo domicilio su estudio, la clausura dispuesta no parece el medio razonable para asegurar lo que el Juez de primera instancia pretende asegurar, para posibilitar las investigaciones.

Puede correctamente disponer el allanamiento de un domicilio o estudio profesional, como así también la incautación de elementos aptos para la investigación de un delito, pero no ordenar la clausura de ese domicilio, entendido éste en el concepto amplio que le reconoce la doctrina y la jurisprudencia.

cia. Por ello, la Cámara considera que, la decisión del inferior ha sido con desmedro claro a los derechos de un tercero y frente a la presentación judicial de éste, no ha dado la respuesta procesal adecuada a las circunstancias.

Apoyando esta tesis, se recuerda que el amparo, saludable creación de la Corte Suprema, tendió a la reparación de derechos esenciales, cuando no existe trámite que resuelva idóneamente el problema, y precisamente dijo: "Sin tomar en cuenta el origen de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados" (Fallos 241:291- Caso "Kot").

III. Que por último, la Cámara plantea el interrogante de si la acción intentada debe ser acogida. Para comenzar a dilucidar la cuestión, menciona que de las constancias arimadas por el actor y del propio informe del Juez Federal de San Juan, surge que ante la clausura del estudio jurídico del actor, éste solicitó en el expediente el levantamiento a fin de ejercer su profesión, y recibió soluciones dilatorias que prolongan el agravio al limitar sus derechos para ejercer su profesión de abogado. También aclara que la sustanciación de recursos procesales de reposición y apelación subsidiaria, si bien en principio aparecen como medios idóneos, no lo serán luego, por la dilación temporal que los mismos suponen.

Que resulta de ello, una lesión constitucional que aparece como grave, grosera y que la Cámara considera que judicialmente debe proveerse el remedio que corrija el error, ya sea conforme a la ley reglamentaria o en una interpretación de ella, pero que con criterio se ajuste sustancialmente a la Constitución. Por último, sostiene que la clausura aparece clara y burdamente arbitraria e ilegítima, y que los remedios ordinarios recursivos no permitirían la reparación en forma inmediata, idónea y útil para la tutela de los derechos constitucionalizados en juego.

Por todo ello, la Cámara resuelve, hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Dr. Soler y disponer el levantamiento de la clausura del estudio profesional del mencionado abogado en el término de tres horas, sin perjuicio que el Juez disponga la requisa de la documentación o elementos que estime pertinentes y con las formalidades de ley.

Suscriben la decisión los jueces Carlos M. Pereyra González, Guillermo M. Petra Recarbarren y Eduardo Mestre Brizuela.

e.3) "Miró Héctor D. s/ acción de amparo", expte. 43.912, 4/8/1959

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires entiende en la presentación de una acción de amparo, contra la medida restrictiva de la libertad dispuesta en el juicio "Haegogar Motor c. 24 de octubre s/ interdicto de obra nueva".

De la lectura del fallo analizado, surge que la Cámara de Apelación 1a. en lo Civil y Comercial de Mercedes, ordena la detención del recurrente, dejando sin efecto el carácter sustitutivo de la multa que impusiere oportunamen-

te, pese al depósito de su importe por parte del sancionado y alegando persistencia en la actitud irrespetuosa de éste hacia el tribunal. A su vez, la Cámara obliga a constituirse en detención, como condición para ser oído.

Con todo ello, la acción de amparo llega a la Corte, expidiéndose la misma, en razón de que si bien carecería de jurisdicción para conocer en recursos interpuestos contra restricciones de la libertad individual, cuando los mismos se deduzcan por vía del recurso de habeas corpus reglamentado en los arts. 415 y sigtes. del CPPN, no es menos cierto que en circunstancias excepcionales en que el bien jurídico afectado por resolución de una Cámara de Apelación —restricción a la libertad individual— no tiene remedio admisible por aquella vía, a pesar de la posible vulneración de la garantía constitucional que lo respalda, la protección de los órganos jurisdiccionales ha de tender a sustentarlo, cuando el recurso interpuesto es el de amparo y se funda como en el caso en el art. 18 de la Constitución Nacional y arts. 9°, 13, 14 y 44 de la Constitución de la provincia.

Para fundar su veredicto, la Corte, cita el conocido pronunciamiento de la CSJN en la causa "Kot, Samuel" donde ha considerado que "...toda privación ilegítima de la libertad personal sin distinción alguna de quién emana, autoriza el amparo de la Constitución... De otro modo habría que concluir que los derechos esenciales de la persona humana carecen en el derecho argentino de las garantías indispensables para su existencia y plenitud, y es obvio que esta conclusión no puede ser admitida sin serio menoscabo de la dignidad y del orden jurídico de la nación". La Corte sostiene que la decisión adoptada por la Cámara, ha transgredido el art. 16, inc. 3° del Cod. de Proced., en cuanto le acuerda facultades disciplinarias, imponiendo directamente una sanción que sólo tiene carácter supletorio. Que a su vez, la obligación, que le impone de constituirse en detención para ser oído, importa invadir el campo del derecho represivo, vedado a la justicia en lo civil y comercial, aún en uso de facultades disciplinarias que no sancionan delitos, ni constituyen una pena.

Por lo tanto, la Corte resuelve, hacer lugar al recurso deducido y dejar sin efecto la medida restrictiva de la libertad dispuesta.

e.4) "Ibarra, Absalón s/ recurso de amparo"

Síntesis de lo que resuelve el Juez de Primera Instancia de la Provincia de Misiones: El Juez de Paz a cargo del Juzgado N° 2, sin oír a la contraparte y por las solas manifestaciones de la actora, que es Sofía Toledo, ordena que se constituya un empleado del Juzgado en el inmueble, propiedad de Ibarra, proceda a la apertura del mismo, compruebe qué bienes existen y los separe, entregando a Sofía Toledo los que le corresponden. Es importante mencionar, que la actora y el Sr. Ibarra habían vivido maritalmente. La actora presta caución para ello, e inmediatamente se realiza la medida ordenada. Una vez que Absalón Ibarra regresa a su casa, y pretende ingresar a su domicilio, se encuentra con que la llave de la cerradura de la puerta principal no funcionaba y que el candado de una puerta trasera había sido violentado, advirtiéndole al entrar en la casa la falta de una serie de efectos. En forma inmediata,

ta, el Sr. Ibarra efectúa la pertinente denuncia ante la Policía, averiguándose en ese momento que los actos de los cuales se agravia, fueron ejecutados por orden del Juez de Paz a cargo del Juzgado N° 2. Ante ello, se presentó en el Juzgado de Paz, comprobando así, que el Juez era quien había dado la orden para que Sofía Toledo entrase en su casa y retirara los efectos. Por lo tanto, hizo el reclamo ante el Juzgado aludido, resolviéndose que le devuelva lo inventariado en las actuaciones promovidas, no así las demás cosas que la Sra. Toledo se llevó sin dejar constancia de ello en el inventario.

Resumidamente, el reclamo del Sr. Ibarra versa sobre los siguientes puntos: que no se le haya dado intervención en el trámite, invoca las disposiciones constitucionales, pide la nulidad de las actuaciones, solicita se enjuicie al Juez actuante y al Oficial de Justicia y se le restituya la propiedad de los muebles de los cuales dice haber sido despojado, presentando una acción de amparo tendiente a que se repare el agravio que el mismo ha sufrido.

Entonces, el Superior Tribunal de Misiones se expide a través de sus diversos integrantes, y por lo tanto cabe hacer una breve reseña de las cuestiones más destacadas que se mencionan en los distintos votos: El Dr. Orlando Gil Navarro al momento de expedirse, dijo: Que aun cuando no está reglamentado el recurso de amparo, que prevén los arts. 16/18 de la Const. Prov., el mismo debe funcionar cuando de defender los derechos fundamentales de los habitantes se trata, como bien lo dispone el art. 18 de la precitada Constitución y la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los casos "Siri" y "Kot", diciendo que: "Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera de alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del recurso de amparo". También opina el vocal, que el Juez debe ser sumamente prudente en su actuación, siendo la concesión de lo petitionado precedida de un minucioso examen de las características del caso. Asimismo, considera que para que proceda un recurso de amparo, tienen que darse en el caso producido y que lesiona derechos personales reconocidos por la Constitución, los siguientes presupuestos: A) La lesión inferida debe ser manifiesta y violatoria de incuestionables derechos constitucionales. B) Debe provenir de la autoridad pública, ya sea el legislador, el poder administrativo o el Poder judicial. C) El acto lesivo no puede ser reparado por los medios establecidos en las leyes, o de poder serlo el remedio llegaría demasiado tarde y la lesión se transformaría en irreparable. Entonces, en el caso deducido ha habido, sin duda alguna, una lesión inferida al recurrente y la misma afecta derechos constitucionales, tales como los de la propiedad y de la defensa en juicio, y además tal lesión se encuentra probada, siendo evidente que el acto judicial no es tal, sino que resulta ser un simple acto arbitrario. También surge de las constancias, que la violación del derecho que antes mencionaba, proviene de la autoridad pública; quedando sólo por averiguar si se cumple el último de los requisitos para que proceda la acción de amparo, por lo tanto cabe preguntarse si esa lesión tiene otro remedio, además del intentado. El Dr. Gil Navarro, opina que una rápida vista del expe-

diente, señala la falta de actividad en que incurre el lesionado: ya que al presentarse, debió pedir la nulidad de lo actuado, y no lo hizo. Luego el Juez, le niega su petición, y no lo apela. De ello se deduce, que cuando Ibarra tuvo oportunidad de intervenir en el proceso, no intentó ninguno de los medios que le ley le proporcionaba, para la defensa de sus derechos; no dándose, de este modo, el último de los requisitos para que proceda la acción intentada. Por último el vocal refuta la objeción que podría hacerse en cuanto a que, el rechazo del recurso interpuesto implicaría dar un "bill de indemnidad" al Juez que actuó desaprensivamente, diciendo que la finalidad del recurso no es la de sancionar a la autoridad que ha causado un desorden jurídico, ya que hay efectivamente otros caminos para sancionarlo.

Por todo lo antes expuesto, el Dr. Gil Navarro, resuelve no hacer lugar al recurso de amparo deducido por Absalón Ibarra, sin costas, atento a la naturaleza de lo cuestionado.

El Dr. Lampugnani, dijo: Que respecto de la primera cuestión planteada, en cuanto a si la sentencia apelada era nula; el mismo advirtió que el recurso de apelación comprende al de nulidad. Que a su vez, no se advertían vicios ni omisiones sustanciales de procedimiento que autorizaran a declararla de oficio, por lo tanto correspondía su desestimación.

El Dr. Alvarenga adhirió al voto precedente.

Ahora, ante la cuestión de si es arreglada a derecho, el Dr. Lampugnani señaló que en la Constitución provincial de Misiones el recurso de amparo tiene gran amplitud conceptual, ya que puede ser intentado frente a cualquier decisión o acto arbitrario "de la autoridad", ya sea con relación a la persona, como así también a los derechos de los habitantes de la provincia, conforme se trate de una lesión jurídica consumada, como de una amenaza inminente. En este caso procede el recurso a fin de lograr que cese el efecto de lo ya sucedido o no se pueda concretar lo amenazado. Por cuanto el vocal señaló, que no hay duda alguna en que la acción procede aún contra una decisión judicial, en determinadas circunstancias y esto surge del texto expreso de la Carta Constitucional. También aclara el Dr. Lampugnani, que no debe verse al recurso de amparo como un sanalotodo, en virtud de que siempre debe tenerse en cuenta que este es un medio excepcional que no será viable en tanto se esté en presencia de determinadas circunstancias bien objetivadas; y esto se debe a que el poder judicial tiene asegurados legales recursos, por lo general suspensivos respecto de sus decisiones con incidencia gravosa e inconstitucional. Por ello es así que, la vía excepcional del amparo sólo se introducirá en procedimientos judiciales en caso de que en el trámite corriente, no exista remedio alguno para atacar el acto arbitrario o ilegal, o bien de existir los mismos, éstos llegarían demasiado tarde, pudiendo quedar vulnerada alguna garantía constitucional. Entonces, de acuerdo a ello, el Dr. Lampugnani señala que en el caso de referencia, el recurrente no tenía un medio más idóneo para reclamar su derecho, que no sea el amparo interpuesto, ya que las actuaciones estaban fuera de derecho y no cabían los recursos normales. Esto debido a la actuación inequívoca del magistrado interviniente. A su vez,

el vocal concuerda con la opinión del Dr. Fiorini, al decir que el acto del magistrado, administrador y también del legislador, sin el debido proceso formal permite la interposición del recurso. Concluyendo así, el Dr. Lampugnani, en que el recurso de amparo interpuesto por Ibarra debe ser acogido.

El Dr. Alvarenga, respecto de esta segunda cuestión planteada, dijo: Que fueron las acciones de Sofía Toledo, las que indujeron al oficial de justicia y motivaron la violación del domicilio de Ibarra y el apoderamiento de parte de Toledo de pertenencias de su ex pareja. Respecto de ello, el vocal considera que no puede no puede reprochársele al Juez y al Oficial de Justicia su actuación, ya no cabía una acción de desalojo de una casa deshabitada. Además, aclara que la casahabitación de Ibarra está accesible para él, sus ropas y otras pertenencias fueron rescatadas y para las que no las fueron existen recursos legales comunes que puede ejercitar para conseguirlos. También el embargo preventivo ampara el derecho de recuperar sus enseres y lo desaparecido puede repetirse con la acción de daños y perjuicios. Por último, señala que el amparo debe concederse en ocasiones restringidas, cuando la urgencia del caso y en ausencia de disposiciones o recursos legales comunes para proteger los bienes materiales. Por todo ello, el Dr. Alvarenga vota que la sentencia apelada debe ser confirmada en todas sus partes.

El Dr. Canóves, se adhirió al voto del Dr. Lampugnani.

Finalmente, de acuerdo a los resultados arrojados en la votación, se resolvió revocar en todas sus partes la sentencia apelada, resolviendo sobre el fondo de la cuestión y así hacer lugar al recurso de amparo, declarando la nulidad de lo actuado en el expediente. Y en consecuencia ordenar al Juez provincial de paz a cargo del Juzgado, que restablezca la situación de las partes al estado anterior a las mencionadas actuaciones. Por último, disponer que se extrajeran testimonios de las piezas pertinentes del expediente, a efectos del correspondiente sumario.

14. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos realizado una pequeña introducción en las principales características de la acción de amparo, realizando un lineamiento de sus requisitos de procedencia, su evolución histórico-jurisprudencial y su recepción legislativa y constitucional con sus consecuentes problemáticas.

Y a modo de recapitulación señalamos los siguientes puntos de importancia:

1. La admisibilidad del amparo no requiere agotar la vía administrativa.
2. La existencia de otros medios judiciales descarta la acción de amparo aunque pueda utilizarse cuando hubiese un daño grave e irreparable y cuando la existencia y empleo de remedios judiciales impliquen demoras o inefi-

cacias que neutralicen la garantía. En Video Club Dreams (Fallos 318:1154), la Corte sostuvo la evaluación de la relación entre la dimensión del agravio y la eficacia de otros medios procesales disponibles es materia de decisión judicial en el caso concreto (38). El actor debe invocar y demostrar la ineficiencia de los otros medios judiciales, la urgencia y que el amparo evitará el daño grave e irreparable si se siguieran las otras vías judiciales; y el demandado que la vía del amparo no es apta porque se necesita un mayor debate o prueba.

3. Desde la institucionalización de la República Democrática el amparo no es instrumento de control de políticas macro pero sí lo es para las micro decisiones que afecten derechos sustantivos.

4. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Aquí se produce una importante innovación en el art. 43 de la CN, respecto de lo dispuesto en la ley 16.986 siguiendo el criterio que la Corte había ya sentado en el caso Outon (Fallos: 267:215), aunque no se aclara si abarca la declaración de oficio de inconstitucionalidad, aunque nosotros nos inclinamos por la postura positiva, atento a que el art. 43 dice que el juez "puede" y no aclara que "debe" ser "a pedido de parte".

5. La legitimación del accionante en la acción individual de amparo corresponde a toda persona de existencia visible o de existencia ideal, sea o no habitante del país.

6. Se crea el amparo colectivo. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

7. En las acciones que tienen a proteger derechos subjetivos o intereses legítimos de incidencia colectiva o difusa están legitimados: el afectado (que se agregó al dictamen de la Comisión en el debate de la Convención), el defensor del pueblo y las asociaciones defensa de aquellos fines. También lo tiene el Ministerio Público (art. 120 de la Constitución). No abarca el interés simple. No se reconoce, en principio, legitimación activa a los legisladores, como representantes del pueblo.

8. El afectado es quien sufre lesión en sus derechos subjetivos y quien es tocado, interesado, concernido, y vinculado por los efectos del acto u omisión lesivos, como señalan los precedentes de los casos Kattan, Alberto, de 1983, ED 105-245 y Ekmekdjian c. Sofovich, de 1992, Fallos 315:1492.

9. No se trata, sin embargo, de una acción popular. Ha servido para solucionar problemas de micro políticas cuando el Estado no cumple con sus deberes y se afectan derechos a la vida, a la salud, a los menores, la familia,

(38) CARNOTA, WALTER F., "Dos visiones...", art. cit.

pero no para frenar un proyecto de ley; pero si fuera sancionado y es lesivo puede dar lugar a un amparo.

10. Se admitió la legitimación de una asociación aunque no esté registrada, por no haber ley reglamentaria como resolvió en el caso Mignone, fallo 2807/2000, la Cámara Nacional Electoral.

11. Se trata, en principio, de un proceso unilateral, y la malversación del instituto lo ha llevado a ordinarizarlo, transformándolo en un proceso bilateral lento y sin la respuesta expedita y rápida que requiere.

12. Se hace necesario una reglamentación a través de un Código de Garantías Constitucionales como el de Tucumán.

13. Que el amparo no tenga plazo para su iniciación no ayuda al instituto sino por el contrario lo altera y lo generaliza. Aunque compartimos la idea de considerar exiguo el plazo de 15 días dado por la ley, por lo que resultaría más acercado a la realidad duplicar ese plazo, es decir, 30 días hábiles.

14. La demanda de amparo no puede establecerse contra decisiones del Poder Judicial, pues no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, ni a reiterar cuestiones resultantes definitivamente por ellos.

15. Nuestra posición se inclina por considerar la posibilidad de iniciar un amparo tan solo en cuestiones en que el Poder Judicial actúa en funciones administrativas. Como podemos observar, nuestra jurisprudencia es reacia a conceder el recurso de amparo contra decisiones judiciales; sólo lo hacen en contadas ocasiones.

16. Entonces, como dijimos anteriormente, tanto la mayoría de la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que el amparo es un medio excepcional, que solo procede en limitados casos y en determinadas circunstancias. Es por ello que son pocos los fallos donde los jueces hacen lugar al amparo intentado contra decisiones judiciales.

CAPITULO IV.2

EL AMPARO COLECTIVO

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Antecedentes del amparo colectivo. a) Constitución de 1853-60. b) Jurisprudencia nacional. c) Incorporación constitucional. — 3. Derecho a un ambiente sano apto para el desarrollo humano. — 4. Legitimación o sujeto activo. a) El afectado. b) El Defensor del Pueblo. c) Asociaciones registradas. — 5.- Efecto "erga omnes" de las sentencias de incidencia colectiva. — 6. La creación de un verdadero amparo ambiental. — 7. Consideraciones finales.

1. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional de 1994 agregó un nuevo capítulo de derechos y garantías (arts. 36 a 43). Entre ellos, incluyó a los denominados "derechos de incidencia colectiva" (arts. 41, 42 y 43).

A fin de precisar y delimitar este concepto, tomaremos uno de ellos: la materia ambiental.

En efecto, el art. 41 establece que "... Todos los habitantes gozan del derecho a un *ambiente sano*, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley...". "...Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...". "...Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales...". "... Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

El derecho a un ambiente sano también se encuentra regulado en el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los arts. 26 al 30 de la

237

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otros textos provinciales.

Ahora bien, este derecho tiene en esta década una trascendencia de una magnitud tal que el que lo viola, vulnera o daña es considerado que ha cometido una suerte de "delito social", pues afecta las bases de la existencia social económica, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales y pone en peligro las formas de vida en cuanto implica la destrucción de sistemas de relaciones entre el hombre y todo lo que lo rodea.

Pero ello no tendría consecuencias reales si no se cuenta con una herramienta que permita accionar en defensa y protección del ambiente. Aquí la doctrina es coincidente en afirmar que sin duda la modalidad más novedosa para nuestro derecho público, en materia de garantías, incorporada por la reforma constitucional es el denominado "amparo colectivo", es decir aquella vertiente del amparo que tutela a los derechos de incidencia colectiva — como ser el ambiental — que prevé el art. 43, párrafo segundo de la CN, donde establece: *"...Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización..."*.

Como podemos deducir, el art. 43, nos dice "... esta acción...", haciendo referencia a una ampliación del amparo individual o clásico, descripto y regulado en el primer párrafo del mismo artículo. Esta extensión involucra a tres elementos de la relación jurídica procesal y sustantiva: los derechos, bienes jurídicos u objetos protegidos, los sujetos legitimados para su interposición y los efectos de sus sentencias.

Sin perjuicio de ello, nos queda el siguiente interrogante a resolver: ¿tiene el amparo ambiental rasgos diferentes al amparo clásico, o individual (1)?

Por lo tanto el presente capítulo además de establecer los antecedentes de este instituto, trata la verdadera extensión jurídica y fáctica de los tres elementos citados, hoy a 14 años de su incorporación en nuestra Constitución Nacional, todo ello en aras de mejorar los derechos de la sociedad para un real y eficiente bienestar general.

(1) El amparo individual es aquel que protege los derechos que llevan el mismo nombre, que son tales como: la vida, la salud, el trabajo, la dignidad, la intimidad, entre muchos otros. Pero siempre que no sean los derechos a la libertad física ambulatoria o en el caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, ya que, su protección o garantía se encuentra dentro del conocido *habeas corpus*. Con la reforma de 1994 se le ha sumado los derechos a los datos personales que es protegida por el *habeas data*. Todos ellos regulados en el art. 43 de la Constitución Nacional.

2. ANTECEDENTES DEL AMPARO COLECTIVO

a) Constitución de 1853-60 (2)

Si bien se cree que los derechos incidencia colectiva y su garantía respectiva (amparo colectivo) nacen de la reforma de 1994, al incorporar los arts. 41, 42 y 43 de la CN, una correcta interpretación histórica nos indica que éste tuvo un nacimiento incipiente en la Constitución de 1853-60.

Una de las reformas propuestas por la Convención revisora de la Provincia de Buenos Aires de 1860 —tomando como base a la Constitución de EE.UU.— fue la incorporación de una cláusula que contemplase los derechos implícitos (art. 33 de la CN) (3).

Más allá de las apreciaciones que realizan Sarmiento y Vélez Sarsfield acerca de la naturaleza iusnaturalista de la norma propuesta (4), es la polémica Estévez Seguí – Bartolomé Mitre (acerca de la conveniencia de la incorporación del artículo de los derechos implícitos) la que realiza un gran aporte a la existencia histórica de los derechos colectivos.

Bartolomé Mitre le responde a Estévez Seguí (quien se oponía a la incorporación de la cláusula constitucional sosteniendo que la fórmula del art. 19 de la CN abarcaba a todos los derechos que pueden asistir a los habitantes de la Confederación) y pronuncia las siguientes palabras:

"..Si el Sr. Diputado hubiera consultado por los elementos del derecho y hubiera dividido las cosas, las personas y las acciones, habría prescindido de las personas y se habría fijado en las cosas; habría advertido que es uno de los puntos en que el derecho moderno ha enseñado más, porque no sólo legisla para el individuo, sino para el pueblo como entidad colectiva; no sólo legisla para la soberanía individual de cada hombre, sino para ese ser moral que se llama sociedad, y que científicamente hablando tiene derechos distintos y distintos modos de legislar. Bien pues, todos estos derechos no pueden estar comprendidos en ese artículo que dice: 'ningún habitante del Estado está obligado a hacer lo que la ley no manda'. Eso es del derecho personal, pero los diversos ejemplos que citan los miembros de la Comisión, no provienen de acciones particulares, sino de facultades que pueden abrogarse los Gobiernos respecto de los pueblos....".

(2) MARANHILLO, PATRICIO ALEJANDRO: "Génesis y actualidad del Amparo Colectivo en la República Argentina", Revista Jurídica del Perú, Lima, octubre de 2003.

(3) Este artículo fue incorporado en el año 1860 y tuvo como fuente la enmienda IX de la Constitución de los EEUU. V. CARNOTA, WALTER F., "Los derechos implícitos y las tradiciones jurídicas (A propósito del bicentenario del 'Bill of Rights' norteamericano)", en JA, 30/5/1990, ps. 1 y sigtes.

(4) V. el análisis que del modelo originario hace FARBER, DANIEL, *Retained by the People (The "Silent" Ninth Amendment and the Constitutional Rights Americans don't know they have)*, New York, 2007, ps. 21 y sigtes.